

法律职业资格考试刑法真题归类精解（回忆版）

（2018-2023 年）

《刑法分论》

一、侵犯个人法益的犯罪

（一）侵犯人身权利罪

1. 甲男为强奸乙女，对其实施暴力行为。练过散打的乙女将甲制服后，欲将其扭送至公安机关，甲男为逃跑将乙女捅成重伤。下列说法正确的是？（ ）（多选）

A. 甲男带着奸淫目的对乙女实施了暴力行为，虽然致乙重伤，导致了加重结果，但结果加重犯不存在未遂，因此甲构成一般强奸罪的既遂

B. 虽然犯盗窃罪为抗拒抓捕而当场使用暴力致人重伤，应以抢劫罪致人重伤论处，但不能基于此种认识而对甲定强奸罪致人重伤

C. 根据刑法通说，强奸罪的实行行为致人重伤的，应以强奸罪致人重伤论处，因此对甲强奸罪致人重伤论处

D. 甲带着奸淫目的实施暴力行为，但是因意志以外的原因未得逞，以强奸罪的未遂论处，与故意伤害罪数罪并罚

参考答案：B，D

解析：“强奸致人重伤、死亡”这一结果加重犯，是指因强奸妇女、奸淫幼女导致被害人性器官严重损伤，或者造成其他严重伤害，甚至当场死亡或者经治疗无效死亡的，对于强奸犯出于报复、灭口等动机，在实施强奸的过程中，杀死或伤害被害妇女、幼女的，应分别定为强奸罪、故意杀人罪或者故意伤害罪，按数罪并罚惩处。因此，只有出于“奸淫目的”使用暴力，导致重伤、死亡结果时，才能成立强奸罪的结果加重犯。出于其他目的使用暴力的，应当成立故意杀人罪或故意伤害罪，与前面的强奸罪数罪并罚。

A 项：本案中，甲是出于抗拒抓捕的目的而非出于奸淫的目的实施暴力行为，因此不能将暴力行为所导致的重伤后果认定为强奸罪的加重结果。换言之，甲不是基于强奸行为本身导致了被害人重伤，不能认定为是强奸罪的结果加重犯。因此，A 项错误。

B 项：《刑法》第 269 条规定：“犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条（抢劫罪）的规定定罪处罚。”这一条属于法律拟制规定，对于法律拟制的规定，不能将其适用推而广之。也就是说，盗窃后为了抗拒抓捕而使用暴力，根据《刑法》第 269 条的规定应认定为抢劫罪，将前、后行为综合评价为抢劫罪，是刑法的特别规定。如果没有《刑法》第 269 条这一特别规定，就应认定为盗窃罪与故意伤害罪并罚。但是，对于强奸之后使用暴力抗拒抓捕，前、后行为本身就是独立的两个行为，不能综合评价为强奸致人重伤，应以强奸罪与故意伤害罪并罚。在本案中，犯强奸罪，为抗拒抓捕实施暴力的，刑法并没有拟制为强奸致人重伤。因此，不能将甲的行为拟制认定为强奸致人重伤罪。因此，B 项正确。

C、D 项：在本案中，乙的重伤结果并非由甲的强奸行为直接导致，而是甲为了逃跑的目的将乙捅伤。因此，甲的行为不成立强奸罪致人重伤，而是应当以强奸罪与故意伤害罪数罪并罚。因此，C 项错误，D 项正确。

综上所述，本题答案为 BD 项。

2. 下列哪项构成了绑架罪中的“杀害被绑架人”？（ ）

A. 以勒索财物为目的控制被害人之后，故意伤害被害人，被害人因重伤而死亡

- B. 绑架被害人之后, 为防止被害人出声, 用毛巾塞住其嘴后离开, 被害人窒息死亡
- C. 为勒索财物而着手绑架被害人, 遭到被害人的激烈反抗, 用绳子直接勒死被害人
- D. 取得赎金后, 已经释放被害人, 因担心被害人报警, 开车追了 3 公里, 杀死被害人

答案: C

解析:

考点: 绑架罪

《刑法》第 239 条第 2 款规定, 犯绑架罪, 杀害被绑架人的, 或者故意伤害被绑架人, 致人重伤、死亡的, 处无期徒刑或者死刑, 并处没收财产。刑法对“杀害被绑架人”规定了重刑, 并作为绑架罪的加重情节。因此, 刑法理论、审判实务对于“杀害被绑架人”进行了限制解释, 以防罪刑失衡。多数观点认为, 认定为是“杀害被绑架人”应符合:

第一, 主观上必须是“故意”杀害被害人。

第二, “杀害”行为必须存在于绑架过程之中, 脱离于绑架之外的杀害行为, 应独立评价为故意杀人罪, 不能认定为是绑架罪的加重犯。

第三, “杀害”行为可以造成被害人死亡结果, 也可以是没有造成死亡结果。主要是考虑到, “杀害被绑架人”与“故意伤害被绑架人, 致人重伤、死亡的”并列适用相同法定刑。根据刑法规定, 绑架过程中, 即便故意伤害被害人仅造成重伤结果的, 也应适用加重法定刑。那么, 绑架过程中, “杀害被绑架人的”就不必解释为必须造成被害人死亡。

A 错误。以勒索财物为目的控制被害人之后, 故意伤害被害人, 被害人因重伤而死亡, 属于“故意伤害被绑架人, 致人重伤”这一加重情节, 适用加重法定刑, 不属于杀害被绑架人。

B 错误。绑架被害人之后, 为防止被害人出声, 用毛巾塞住其嘴后离开, 导致被害人窒息死亡, 属于绑架行为本身过失致人死亡, 不属于杀害被绑架人。杀害被绑架人属于故意杀人, 其中的故意包括直接故意, 也包括间接故意; 其中的杀人行为是指在绑架的过程中杀人, 而且该杀人行为是独立于绑架之外的行为。

C 正确。为勒索财物而着手绑架被害人, 遭到被害人的激烈反抗, 用绳子直接勒死被害人, 属于杀害被绑架人。杀害被绑架人包括在绑架既遂后发生, 也包括在着手绑架时因为被害人反抗等原因发生, 只要是在绑架的过程中杀害被绑架人即可。

该选项中, 行为人因遭到被害人的激烈反抗, 基于杀人故意直接用绳子勒死被绑架人, 属于杀害被绑架人。

D 错误。取得赎金后, 已经释放被害人, 此时被害人已经不在行为人的控制范围之下, 绑架行为已经彻底结束。绑架罪的加重情节“杀害被绑架人”要求在绑架的过程中杀人, 而该选项中行为人因担心被害人报警, 开车追了 3 公里, 才杀死被害人, 已经与绑架无关, 故不属于杀害被绑架人, 应当另成立故意杀人罪, 与绑架罪实行数罪并罚。

综上所述, 本题应选 C。

（二）侵犯财产罪

1. 关于财产犯罪的认定，下列选项中正确的是（不考虑情节或数额）？（ ）（多选）

A. 甲在肉摊小贩身后偷走小贩的剔骨刀，后甲趁乙不备，用剔骨刀割断乙挎包背带，夺走挎包后逃走。甲构成抢夺罪

B. 甲潜入乙的家中偷窃珠宝，看到乙家桌子上的现金不为所动，继续翻找珠宝。后乙回家与甲照面，甲为逃避抓捕，将乙打倒致其轻微伤后逃脱。甲构成抢劫罪的未遂

C. 甲在洗车过程中看到乙车副驾驶座位及车内烟灰缸里有各有一张彩票，甲偷走两张彩票后拿去兑奖，其中有一张彩票中奖。无论是哪张彩票中奖，甲均构成盗窃罪的既遂

D. 甲发现乙将电脑放置在商场一层维修部维修，后趁天黑前往商场门口，甲对清洁工丙说电脑是自己的，丙将电脑交给甲。甲对丙构成诈骗罪

参考答案：B，C

解析：A 项：甲的行为属于携带凶器抢夺，成立抢劫罪。《刑法》第 267 条第 2 款规定：“携带凶器抢夺的，依照刑法第二百六十三条（抢劫罪）的规定定罪处罚。”首先，甲的行为属于“携带凶器抢夺”。携带的核心在于将凶器置于行为人现实的支配之下，可以随时使用。在本案中，甲偷走肉摊小贩的剔骨刀，在客观上可以随时使用凶器，在主观上，甲准备用刀将背包带划断带走，因此主观上具有对物使用凶器的意思。携带凶器抢夺不要求行为人具有对被害人使用凶器的意思，甲对物使用凶器的意思就已经满足“携带凶器抢夺”的要求。因此，甲的行为属于“携带凶器抢夺”。其次，携带凶器抢夺“不要求行为人对被害人使用”所携带的凶器。在本案中，甲用剔骨刀迅速将背包带划断，然后夺走背包的行为，属于携带了凶器但没有使用凶器的情况，因为行为人只是用凶器划断了背包带，并没有用凶器对被害人实施暴力或者进行胁迫。因此，甲的行为属于“携带凶器抢夺”，应以抢劫罪论处。因此，A 项错误。注意：如果行为人直接对人显示、使用凶器，则应认定为普通抢劫罪（第 263 条），而非拟制的抢劫罪（第 267 条第 2 款）。

B 项：《刑法》第 269 条规定了转化型抢劫：“犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条（抢劫罪）的规定定罪处罚。”因此，成立转化型抢劫，要求行为人的前行为“犯盗窃、诈骗、抢夺罪”。首先，甲的行为成立入户盗窃的未遂。张明楷教授认为，虽然入户盗窃没有数额较大的要求，但是其既遂也应当以实际取得财物为准。行为人入户盗窃但分文未取的，只能认定为盗窃未遂。在本案中，甲着手实施入户盗窃行为，但实际上甲分文未取。因此，甲的行为成立盗窃未遂。其次，盗窃罪未遂也可以成立转化型抢劫。张明楷教授认为，“犯盗窃、诈骗、抢夺罪”不要求以既遂为标准，前行为成立盗窃未遂的，依然可以成立转化型抢劫。④在本案中，甲的前行为成立盗窃未遂，甲为抗拒抓捕实施暴力的，成立转化型抢劫。再次，甲的行为成立转化型抢劫的未遂。实务中认为，对于转化型抢劫罪，认定既遂的标准是劫取

财物或者造成他人轻伤以上后果，二者必居其一；而既未劫取财物，又未造成他人轻伤以上后果的，属于未遂。在本案中，甲的行为既未实际取得财物，又仅造成乙轻伤的后果。因此，甲的行为成立抢劫罪的未遂。因此，B 项正确。

2. 甲是某公司的工作人员，公司提供门面出租，甲负责收租金。甲伪造公司公章加盖文件，私自与商家订立租赁合同，并收取商家租金 8 万元。关于甲的行为，下列说法正确的是？（ ）（多选）

- A. 即使认为甲构成职务侵占罪，也不影响甲诈骗罪的认定
- B. 如果认为职务侵占罪的手段不包括骗取、窃取，仅包括侵吞，即使认为甲利用了职务之便，也不影响甲诈骗罪的认定
- C. 即使认为甲构成表见代理，也不影响甲诈骗罪的认定
- D. 即使商家未再向公司重新缴纳租金，也不影响甲诈骗罪的认定

参考答案：ABCD

解析：A 选项：按照刑法理论的通说与司法实践的通行做法，职务侵占罪的行为方式包括利用职务上的便利的窃取、骗取、侵吞公司财产的行为。张明楷教授认为，在不考虑诈骗罪与职务侵占罪入罪数额的情况下，职务侵占罪与诈骗罪不是对立关系，而是特别关系。亦即，骗取型的职务侵占罪均符合诈骗罪的构成要件。故即使认为甲构成职务侵占罪而侵吞了公司的门面租金，也不影响甲诈骗罪的认定。因此，A 选项正确。

B 选项：如果认为职务侵占罪的手段不包括骗取、窃取，仅包括侵吞。那么行为人利用职务上的便利实施的窃取、骗取公司财物的行为，应直接以盗窃罪、诈骗罪论处。本案中，即使认为甲利用了职务之便，也仅仅是利用了职务之便骗取公司财产，而并非基于职务之便“侵吞”自己保管之下的公司财产，不构成职务侵占罪，应以诈骗罪论处。因此，B 项正确。

C 选项：本案中，商家基于错误认识，处分了自己的财产，由于代理人甲成立表见代理，最终的损失由公司承担，所以公司是本案的最终被害人。所以部分同学可能认为，本案中，商家没有损失，公司也没有基于错误认识处分自己的财产，所以甲不成立诈骗罪。事实上，表见代理骗财案，从其行为构造来看，其本质上仍是一种诈骗。此类案件中，基于代理人的欺骗行为，相对人陷入错误认识而向代理人交付财产，被代理人对相对人享有的债权因此予以消灭。然而，被代理人交付了财产或者发生了债务，但未获得财产，因此遭受了财产损失。因此甲应当成立诈骗罪。因此，C 选正确。对犯罪行为的定性，仅存在于“行为当时”，甲在当时实施了欺骗行为，骗取了商家的租金，当然成立诈骗罪（当然，也可能成立职务侵占罪）。而民法上的表见代理，是一种“事后追认权”，其目的是对于一些无权代理，甚至欺诈类的行为，事后肯定其民法上的效力，以保证民事交易的顺利进行，尊重各方的事后意愿。即便民法上通过表见代理的追认，肯定该民事行为在民法上的效力，但也不能否认其刑法上的犯罪。换言之，刑法上已经构成犯罪的行为，不可能通过他人的“事后追认”而否定犯罪的成立，例如，甲强奸乙之后，乙爱上了甲，甲仍然构成强奸罪。

D 选项：首先，如果商家再次向公司支付租金，那么商家就是本案的被害人，甲虚构合同，商家基于错误认识，处分自己的财产。甲成立诈骗罪。其次，即使商家不再向公司支付租金，换言之，公司追认该无权处分合同有效，或甲成立表见代理。此时，商家已然基于错误认识支付了租金，但因为得到了相应的对价（房屋的使用权），没有造成实际损失，但诈骗罪是针对个别财产的犯罪，甲仍然成立诈骗罪。再次，由于甲的欺骗行为，使得本应由公司享有的对商家的债权消灭，造成了公司的损失。张明楷教授也认为这是一种特殊的三角诈骗，构成诈骗罪。总而言之，无论商家是否需要重新缴纳租金，都不影响甲诈骗罪的认定。因此，D 项正确。

综上所述，本题答案为 ABCD 项。

3. 甲是出租车司机，乙是乘客。甲在乙下车前看到了乙准备下车但遗落在后座的高价手机。乙下车后，甲在原地停留了几分钟，但未开口提醒乙，后乙离开。随后甲试了试，打开了乙的手机，将乙银行卡里的三万元转到了乙的微信上，甲给自己购物花费三万元。之后，乙打电话来，甲佯装路人，谎称自己是捡到的手机，随后挂断电话。下列说法正确的是？（ ）（单选）

- A. 乙离开时手机的占有已经转移给了司机甲，甲对手机构成侵占罪
- B. 乙下车时对手机还未脱离占有，甲看到了但不提醒，甲对手机构成不作为的盗窃罪
- C. 甲用乙手机将信用卡中 3 万元转移到乙微信中的行为构成信用卡诈骗罪
- D. 甲佯装路人并欺骗乙是捡来的手机，甲构成诈骗罪

参考答案：A

解析：

A 选项：侵占罪的犯罪对象是代为保管或占有的他人财物。出租车作为一种特定场所，具有一定的封闭性。乘客由于自己的过失，将自有物品丢失在出租车后离开，应当肯定乘客离开出租车后，便已经失去了对物品的占有，同时由于出租车司机有权利对其车内的所有物品进行保管，故该物品作为遗忘物，自然由司机占有。本案中，出租车司机甲发现乘客乙遗失在出租车上的手机，乘机非法占为己有的，应当成立侵占罪。因此，A 选项正确。

B 选项：首先，甲与乙之间仅是运输合同关系，运输合同并没有要求甲，具有提醒乙保管好随身财物的义务。在乙下车时手机还未脱离自己占有，虽然甲发现了手机遗落在车上，但没有通知甲的义务，不成立盗窃罪。其次，当乙离开出租车后，手机的占有权已经转移给甲，而且转移的原因是乙自身的过失。盗窃罪的犯罪对象只能是他人占有的财物，对自己占有的财物不可能成立盗窃罪。试想，如果乙事后发现自己的手机丢在出租车上，向警方报警，是会主张自己的手机丢在车上，还是自己的手机被出租车司机盗窃？因此，B 错误。

可能有同学会对比如下两种情形：（1）如果乘客下车时，站在车旁边，司机发现手机在车上，此时手机仍归乘客占有，司机遂开车逃走，应成立盗窃罪。（2）如果乘客下车后，已经离去很久（如一小时），司机发现手机在车上，手机转归司机占有，司机遂将手机占为己

有，成立侵占罪。而本选项中，可能有同学会认为，乘客在出租车旁边时，手机仍然归乘客占有，乘客离去时就会导致手机脱离乘客本人的占有而转归司机占有，司机有告知手机的义务，不履行该报告义务的，系以不作为方式打破乘客对手机的占有，成立不作为犯的盗窃罪。这种观点确实有一定的道理，但这种观点过于扩张了空间管理者（出租车司机）的义务范围，会导致处罚过重。如果按此理解，甲来徐毛毛家中做客，后来甲忘记将手机拿走而离去，徐毛毛不予提醒；或者，甲在宾馆前台办理入住，忘记将手机放在前台，前台服务员不提醒，进而将财物据为己有的，都成立不作为犯的盗窃罪。不可否认，该类案件中，行为人有返还的义务，不返还的，成立侵占罪，但认定为盗窃罪会导致处罚过重，也扩张了处罚的范围。

C 选项：首先，2018 年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第 5 条第 2 款第 3 项规定，“窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用”，属于信用卡诈骗罪中“冒用他人信用卡”的情形。司法解释中的“通过互联网、通讯终端等使用”应是指直接使用了信用卡的卡号、密码等要素的情形，而不能认为凡是资金最终源于信用卡的使用行为，就是使用信用卡。本案中，甲通过微信，将乙银行卡内的 3 万元转移到乙的微信钱包中，所直接使用是微信的相关资料，而没有直接使用乙的信用卡的卡号、密码等，因而不能认定为使用、冒用他人信用卡。故甲不成立信用卡诈骗罪。其次，对于甲通过乙的微信将乙信用卡内的财产转移到乙的微信钱包这一行为。理论上存在两种意见，一种观点认为，从乙的信用卡中转移出的款项仍在乙的微信钱包中，单纯的转移行为，并没有造成乙的财产损失，故甲不构成犯罪。另一种观点认为，甲使用乙的微信进行转账，表明甲事实上已经掌控了乙的微信，这笔钱离开乙的银行卡之时，已经脱离了乙的掌握，因此甲应当成立盗窃罪。司法实践中多支持第二种观点。总之，无论持哪一种观点，甲的行为不可能成立信用卡诈骗罪。因此，C 选项错误。

D 选项：本选项考察侵占后的侵占问题的定性，即同一行为人反复对同一财物实施侵占行为，是认定为两个侵占罪还是以—个侵占罪论处？对此，张明楷教授认为，存在“侵占”后的“侵占”，但由于前后两次侵占最终只侵害了一个法益，应当以包括的一罪论处，即不再认定后行为成立侵占罪。也就是说，第一步已经侵占了手机，构成犯罪既遂。事后，再以欺骗方式“巩固”之前的“成果”，而不属于打破新的“占有”，不成立诈骗罪，也不成立侵占罪，没有侵害新的法益。因此，D 选项错误。

综上所述，本题答案为 A 项。

4. 国家工作人员甲，让私营企业的员工乙“报销”旅游费用 6 万。乙因有求于甲的职务关系以谋取不正当利益，以自己的工作开支为由从私营企业将这笔费用予以报销，后将报销所得金额全部交予甲。下列说法正确的是？（ ）（多选）

- A. 如果认为职务侵占罪不要求“占有”为自己占有，则乙成立职务侵占罪
- B. 如果认为职务侵占罪要求“占有”为自己占有，则乙成立诈骗罪

C. 甲与乙是行贿罪的共同犯罪，不再对甲定受贿罪

D. 认定职务侵占罪，不仅仅要考虑侵占物的情况，还得考虑行为人是否利用了职务便利

参考答案：A，B，D

解析：A 项：如果认为职务侵占罪中的“占有”不要求行为人自己占有。那么即使行为人本人没有将钱据为己有，而由第三者占有，也不影响行为人非法占有目的的成立。例如，行为人以低价贱卖国有资产（公司资产）给他人，自己并没有得到好处，没有自己占有，如果认为贪污罪（职务侵占罪）的占有，不要求为自己占有，行为人也应成立贪污罪（职务侵占罪）。本案中，虽然乙利用职务上的便利，采用欺诈的方式骗取单位财产后，全部给了甲。虽然乙并未据为己有，但仍成立职务侵占罪。因此，A 项正确。

B 项：首先，如果认为职务侵占要求“占有”仅为行为人自己占有，那么，如果钱由第三人占有，行为人并没有在这一环节得到好处，便不能认定行为人具有职务侵占罪所要求的非法占有目的，故乙不成立职务侵占罪。

其次，本案中，乙虚构自己工作开支的事实，以欺诈的手段骗取单位财产，使得单位（或者单位财务人员）基于错误认识而处分了财产，成立诈骗罪。因此，B 选项正确。

C 选项：行贿罪是指，行为人给予国家工作人员以财物，请求国家工作人员利用职务上的便利，为其谋取利益。但本案中，国家工作人员甲是利用职务上的便利索取财物，而不是利用职务上的便利为他人谋取利益，应当属于受贿罪中的索贿，构成受贿罪。对于这种必要的共犯（对向犯），刑法对双方都规定了独立的罪名，甲成立受贿罪，就不再与乙成立行贿罪的共同犯罪。否则，甲将成立受贿罪与行贿罪的竞合，这也不符合实践，实务中，不可能将甲认定为行贿罪。

因此，C 选项错误。

D 选项：《刑法》第 271 条规定，“公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。”因此，只有行为人利用职务上的便利，才可能成立职务侵占罪。因此，D 选项正确。

综上所述，本题答案为 ABD 项。

5. 甲身穿林业局工作服盗伐林木，其间被多名群众围观，但都认为其是林业部门的工作人员，便没有制止。关于甲的行为，下列说法正确的是？（ ）（多选）

A. 如果认为盗伐林木罪是盗窃罪的特别法条，甲不构成盗伐林木罪，但构成盗窃罪

B. 如果认为盗伐可以以公开方式进行，则甲的行为构成盗伐林木罪

C. 虽然甲在客观上公开砍伐，但其隐瞒身份，仍然属于“秘密”，故甲的行为成立盗伐林木罪

D. 甲构成招摇撞骗罪

参考答案：B，C

解析：A 项：如果认为盗伐林木罪是盗窃罪的特别法条，即二者是法条竞合关系，那么根据特别法优于一般法的原则，甲的行为只能成立盗伐林木罪，不构成盗窃罪。如果甲未达盗伐林木罪所要求的定罪标准，就不能认定为犯罪，也不应当成立盗窃罪。故 A 错误。对此，张明楷教授也有不同观点，但并不影响对本选项的判断。张明楷认为，即使人们坚持认为盗窃罪（法定最高刑为无期徒刑）与盗伐林木罪（法定最高刑为十五年有期徒刑）是法条竞合的特别关系，那么，按照不法的包容性的实质标准，这种特别关系（法条竞合关系）仅限于盗伐林木的财物价值（不法程度）没有超出 15 年有期徒刑程度的情形。换言之，当盗伐林木所造成的财产侵害程度需要判处无期徒刑时，其与盗窃罪之间便是想象竞合。这是因为，如果仅认定为法条竞合的特别关系，就没有对重大财产侵害这一不法内容进行充分评价，而仅认定为盗窃罪就没有评价对森林资源的侵害内容。只有认定为想象竞合，才有充分评价行为的不法性质与不法内容。其实，张明楷教授本人的想法是，如果盗伐了数量特别巨大的林木，就不宜认定为盗伐林木罪（法定最高刑只有 15 年有期徒刑），而应认定为盗窃罪（法定最高刑为无期徒刑）。但是，这是建立在两罪是想象竞合这一前提之下，才能得出的结论。而 A 选项中，说二者是特别法条与一般法条的关系，即法条竞合关系，那就应绝对坚持特别法优先，认定为盗伐林木罪。因此，A 项错误。

B 项：盗伐林木罪的保护法益是森林资源及其合理利用以及国家、集体、他人对生长中的林木的财产所有权。基于此，有学者认为，盗伐可以以公开方式进行。那么，根据此种观点，只要林木在客观上被砍伐，无论行为人是在他人的注视下还是秘密砍伐，都应成立盗伐林木罪。②因此，B 项正确。

C 项：秘密和公开是相对于财物的所有人或保管人来说的，而不是针对大众。即使行为人的行为在客观上是公开的，但行为人自认为采取了一种背着财物的所有人或保管人的行为，尤其是未被被害人发现，也可以认为是秘密。例如，路边停了一辆徐某的自行车，毛毛假装是自行车的主人，坐在自行车上，然后慢慢地打开车锁，骑走自行车。周围的人都以为毛毛是自行车主人，也可以认为其是隐瞒了自己的身份（非车主的身份），但仍然是秘密窃取。本案中，如 B 项所述，盗伐林木罪的保护法益是森林资源及其合理利用以及国家、集体、他人对生长中的林木的财产所有权。甲虽然在客观上公开砍伐，但由于其隐瞒了自己的真实身份，主观上并不想让他知道其在非法获取财物，仍然属于“秘密”，故甲的行为成立盗伐林木罪，C 正确。

D 项：招摇撞骗罪的实质在于：“冒充”+“骗”。冒充之后，再去实施欺骗行为的，即干坏事，这才会损害国家机关工作人员的形象。本案中，甲只是穿着林业局的工作服，虽然盗伐了林木，但是其并没有实施欺骗行为，不能认为构成招摇撞骗罪。因此，D 项错误。

综上所述，本题答案为 BC 项①

6. 在公交车上，歹徒甲看中乘客乙价值 5000 元的手包，在公交车到站准备开门的时候，

夺过手包就跑下车，乘客乙追着不放，好心的乘客丙也帮忙下车追赶甲。跑出 200 米后，甲拿起旁边水果摊的水果刀威胁丙：“再过来我就不客气了。”丙毫不示弱，拼死抢回手包。关于甲的行为，下列哪一说法是正确的？（ ）

A. 甲的行为构成转化型抢劫罪（《刑法》第 269 条），不适用“在公共交通工具上抢劫”这一加重处罚情节

B. 甲的行为仅构成抢夺罪

C. 甲的行为构成抢劫罪，属于“在公共交通工具上抢劫”

D. 甲的行为仅构成抢夺罪，因为后续的暴力行为并没有造成被害人轻伤以上，不能转化成抢劫

答案：A

解析：

考点：抢劫罪

ABC 三项，本案中，该案中，行为人的前行为是抢夺，后使用暴力相威胁而抗拒抓捕，应成立刑法第 269 条的转化型抢劫（事后抢劫）。但是在公共交通工具上抢劫应作限制解释，强调暴力、胁迫发生在公共交通工具内，甲的暴力、胁迫行为并没有发生在公共交通工具上，因此其行为不构成在公共交通工具上抢劫，不适用在公共交通工具上抢劫这一加重处罚情节。

D 项，成立转化型抢劫，不需要造成被害人轻伤以上。暴力应具有足以使他人不敢反抗、不能反抗的程度，即与普通抢劫罪的暴力程度相当。如果程度极其轻微的，不能转化为抢劫罪。综上所述，本题应选 A。

7. 甲在公交车上抢夺张某的钱包，夺下钱包后就跑下公交车。正好路过该处的民警乙看到甲在逃跑，便追赶甲。之后甲、乙两人扭打在一起，甲逃往马路对面，民警乙在追赶过程中被车辆撞身亡。下列说法正确的是？（ ）

A. 甲的行为构成抢夺罪，不需要对乙的死亡结果负责

B. 甲的行为构成抢劫罪，不需要对乙的死亡结果负责

C. 甲的行为构成抢劫罪，是抢劫致人死亡的结果加重犯

D. 甲的行为构成抢劫罪，属于在公共交通工具上抢劫

答案：B

解析：

考点：抢劫罪、抢夺罪

第一，甲在抢夺后，为了抗拒抓捕而对前来追赶的警察使用暴力，根据《刑法》第 269 条的规定，应转化为抢劫罪。A 错误。第二，甲的行为不属于在公共交通工具上抢劫这一加重犯。司法解释规定，要成立《刑法》第 269 条的转化型“在公共交通工具上抢劫”，要求前行为（盗窃、诈骗、抢夺）与后行为（暴力、胁迫手段）均发生在公共交通工具上。本案

中的暴力行为并非发生在公共交通工具上。D 错误。第三，甲的行为不构成抢劫致人死亡的结果加重犯。乙的死亡结果不应由甲负责。谁支配风险，谁对危害结果负责。本案中，追赶者乙的风险更多地是取决于乙本人，乙本人是风险的直接掌控者。B 错误。

综上所述，本题应选 B。

8. 下列哪些行为，甲的行为构成抢劫致人重伤？（ ）

- A. 甲抢劫徐某后逃跑，被害人徐某追甲，在追赶甲的过程中，摔成重伤
- B. 甲抢劫孟某后逃跑，孟某抓住甲的手不放，甲将孟某推开的过程中，过失造成孟某重伤，然后逃离现场
- C. 甲盗窃毛某的财物后被毛某发现并追赶，为了逃避追赶，甲使用暴力抗拒被害人毛某的抓捕，导致被害人重伤
- D. 甲在马某家对马某抢劫的过程中，对被害人马某实施了捆绑，逃跑时忘记为被害人松绑。被害人马某爬到阳台上呼喊时，不慎摔成重伤

答案：BCD

解析：

考点：抢劫罪

A 错误。被害人徐某追赶甲，风险的支配权在徐某手中。徐某应对自身的重伤结果负责，甲不对该重伤结果负责，不构成抢劫致人重伤。

B 正确。抢劫致人重伤、死亡，包括过失的结果加重犯，抢劫行为过失的导致被害人重伤、死亡的，属于抢劫致人重伤、死亡，该情形属于典型的结果加重犯。

抢劫致人重伤，既包括抢劫行为本身造成了被害人重伤、死亡，亦包括在抢劫的机会中致人重伤死亡。亦即，前者是指抢劫行为本身，如排除被害人的反抗以获取财物，进而造成被害人重伤、死亡。后者是指在抢劫行为的直接影响下导致被害人重伤、死亡，例如，抢劫后为了毁灭证据而放火，进而导致被害人死亡；或者，抢劫行为结束后，忘记给被害人松绑，导致被害人被饿死。

本案亦属在抢劫的机会过程中造成被害人重伤，应成立抢劫致人重伤这一结果加重犯。

C 正确。《刑法》第 269 条规定，犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照《刑法》第 263 条关于抢劫罪的规定定罪处罚。

本案中，甲盗窃后，实施了明显的暴力行为以抗拒抓捕，成立抢劫罪（第 269 条转化型抢劫）。

D 正确。本案即属抢劫行为的直接影响下导致被害人死亡，应认定为抢劫致人死亡。

再者，本案中，被害人的手脚被捆住后，其爬到阳台、窗口呼喊、呼救是正常因素，并不异常，不能中断前行为（抢劫行为）与后结果（死亡结果）之间的因果关系，故抢劫行为与被害人的死亡结果之间存在刑法上的因果关系。

综上所述，本题应选 BCD。

9. 某法院将扣押的车辆放在停车场，甲对该停车场的保管员乙谎称自己是法院的人，受法院的委托过来把车开走。保管员乙信以为真，并收取了甲给的保管费后，让甲把汽车开走。下列哪一说法是错误的？（ ）

- A. 甲的行为构成诈骗罪，保管员乙对该车辆有处分权
- B. 甲的行为成立盗窃罪，保管员乙对该车辆没有处分权
- C. 如果甲是该车辆的所有权人，甲通过欺骗方式骗回自己所有的汽车的，若坚持财产罪的保护法益为财产所有权，甲的行为不成立诈骗罪
- D. 如果甲是该车辆的所有权人，甲通过欺骗方式骗回自己所有的汽车的，若坚持财产罪的保护法益为财产占有权，甲的行为成立诈骗罪

答案：B

解析：

考点：诈骗罪

AB 两项，盗窃罪为行为人将他人占有之物占为己有的过程。诈骗罪为被骗人在行为人的欺骗下，将自己有处分权的财物，主动转移占有，从而遭受财产损失的过程。本案中，保管员乙对其保管、占有的车辆有处分权。乙轻信甲之言，将车交于甲，甲的行为构成诈骗罪。

CD 两项，本案中，甲拥有汽车的所有权，法院为汽车的合法占有者。若坚持财产犯罪的保护法益为财产所有权，甲取回的是自己所有的财产，甲的行为不成立诈骗罪。如果坚持财产犯罪的保护法益为占有权，则甲侵犯了法院对该车辆的占有，甲的行为成立诈骗罪。

综上所述，本题应选 B。

10. 甲、乙共谋盗窃丙的银行卡，乙偷窥到丙的密码，甲盗窃了丙的卡。甲去 ATM 取钱，乙帮忙望风掩护，ATM 显示余额有 7 万元，甲取出了 2 万元，但骗乙说卡里只有 1 万元，并分了 5000 元给乙。后甲又自己取了 5 万元。下列说法正确的是？（ ）

- A. 甲成立盗窃罪，金额是 7 万元
- B. 乙成立盗窃罪，金额是 2 万元
- C. 乙成立盗窃罪，金额是 1 万元
- D. 甲对乙成立诈骗罪

答案：AB

考点：信用卡诈骗罪

信用卡为记名且可挂失，盗窃信用卡不等于盗窃到信用卡里面的钱，因此，一般的盗窃信用卡行为不认定为数额较大，不构成盗窃罪，只有在使用时才成立盗窃罪。特殊的盗窃（多次、入户、携带凶器、扒窃）信用卡，不要求数额较大，盗窃信用卡时就构成盗窃罪。本案中，甲、乙共同盗窃信用卡，使用时才成立盗窃罪。乙并没有参与甲后续“使用信用卡”的行为，故乙不对甲的后续行为承担责任。甲的盗窃金额为 7 万元，乙的盗窃金额为 2 万元。第一次用卡的时候，甲虽然欺骗乙说卡里仅有 1 万元，但是，乙确实为甲的取款起到了帮助

作用（望风），甲、乙的内部分赃行为不影响共同犯罪数额的认定。A、B 两项正确，当选。C、D 两项错误，不当选。

综上所述，本题应选 AB。

11. 甲拿着包坐在公园长椅上，乙看着就默默坐他旁边。甲离开时忘记将自己的包拿走，乙见甲离开，迅速将包拿走。甲走出 10 米突然想起了自己的包，返回原处未看见包与乙。下列说法正确的是？（ ）

- A. 乙的行为构成盗窃罪
- B. 甲虽然离开, 但该包仍然归甲占有
- C. 乙的行为构成侵占罪
- D. 甲忘记将该包拿走, 该包就是无人占有的财产

答案：AB

考点：盗窃罪

甲虽然离开，但该包仍然归甲占有，乙拿走包的行为构成盗窃罪。AB 正确，当选。

综上所述，本题应选 AB。

12. 甲、乙二人约定结伴爬山，二人乘坐大巴车前往目的地。在大巴车上，甲看到乙睡着，于是将乙的手机偷出，把乙微信里的余额转到自己账户上，把乙的手机放进自己的背包中，打算下车扔掉乙的手机。下车后，乙问甲是否看到自己的手机了，甲反问是不是落在车上了，乙自认倒霉，后来甲又将乙的手机卖给不知情的丙。下列说法正确的是？（ ）

- A. 甲对手机构成盗窃罪
- B. 甲对微信余额和手机构成两种不同种罪名
- C. 甲对微信余额构成侵占罪
- D. 甲对手机和微信余额构成相同罪名

答案：B

解析：

考点：盗窃罪 侵占罪

甲在大巴上偷偷把睡着的乙的手机拿走，并把乙微信里的余额转到自己账户上，甲的这一行为属于以秘密手段，在乙不知情的情况下，窃取乙数额较大财物，构成盗窃罪。在实务中，偷偷窃取他人微信里的钱、偷偷使用他人支付宝向自己转账，皆认定为盗窃罪。

其次，对手机构成侵占罪。这是因为，甲在一开始获取手机时，并没有非法占有目的。即便其后来有毁坏手机的故意，但事实上并没有实施毁坏的行为，也不成立故意毁坏财物罪。此后，甲将该手机据为己有的（出售该手机给他人，利用了该手机的经济价值，有利用机能），应成立侵占罪。张明楷教授指出：“以毁坏的意思取得他人财物后，没有毁坏财物而是单纯予以放置的，成立故意毁坏财物罪，因为该行为导致被害人丧失了财物的效用。以毁坏的意思取得他人财物并利用的，则成立侵占罪。”

因此，对微信余额成立盗窃罪，对手机成立侵占罪，B 正确。

综上所述，本题应选 B。

13. 甲、乙、丙三人商定后，从淘宝店购买了某品牌的最新款手机 30 部，收到手机后，三人拆下新手机的主板，换上事先准备好的废旧主板，然后利用 7 天无理由退货的规则，将手机退货，从店主处获得全额退款 80000 元。关于甲、乙、丙三人的刑事责任，下列哪一选项是正确的？（ ）

- A. 就手机整体成立诈骗罪 B. 就手机退款成立诈骗罪
C. 就手机主板成立诈骗罪 D. 就手机主板成立盗窃罪

答案：B

解析：

考点：诈骗罪

本案的行为分为两个步骤：

第一个步骤：从淘宝店购买了某品牌的最新款手机 30 部。这是正常的买卖行为，支付了对价，不构成犯罪。即便后续行为人将手机主板换掉，也不构成任何犯罪，这事实上是处分自己的财产。

第二个步骤：用“不完美”的手机(已经被更换了废旧主板)骗取商家，以获取“完美的手机货款”，这一行为应成立诈骗罪。事实上，该行为是利用虚假手段，使得商家处分了手机货款(退款)。

因此，行为人的行为应成立诈骗罪，诈骗金额应认定为是商家处分的财产——手机货款(退款)。

综上所述，本题应选 B。

14. 甲无意购买某土地使用权，却借某房地产公司资质在自然资源局登记竞买，并声称其他公司（有意参与竞买的公司）给其 300 万元便可退出竞买，否则参与竞买。甲两次分别从两家公司获利 600 万元。第三次因无公司参与竞买，甲自己退出竞买。甲的前两次行为构成？（ ）

- A. 强迫交易罪 B. 诈骗罪 C. 敲诈勒索罪 D. 串通投标罪

答案：B

解析：

考点：诈骗罪

A 错误。《刑法》第 226 条(强迫交易罪)规定：“以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的；(二)强迫他人提供或者接受服务的；(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。”

强迫交易的本质在于：让市场经济的主体干了他不愿意干的事情，破坏了交易自愿原则。本题中，甲仅仅是声称若其他公司给其 300 万元便可退出竞买，否则参与竞买，而并没有以暴力或胁迫手段“强迫”其他公司参与或者退出投标，因此甲不成立强迫交易罪。

B 正确。甲虚构了其要参与竞买土地使用权的事实，导致其他公司产生错误认识，并使得两家公司基于错误认识，分别交付了 300 万元给甲。甲的行为完全符合诈骗罪的特征，应以诈骗罪论处。

C 错误。敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对他人实行威胁（恐吓），索取公私财物数额较大或者多次敲诈勒索的行为。在敲诈勒索罪中，必须是行为人的行为使被害人产生恐惧，被害人基于恐惧的心理处分了财产。

本案中，甲并没有对其他公司实施威胁或恐吓行为，甲虽声称若其他公司给其 300 万元便可退出竞买，否则参与竞买。但甲即便参与竞买，也不必然导致其他公司不能竞买成功，甲的行为并不足以使其他公司产生恐惧心理，并因此支付财产。因此，甲不成立敲诈勒索罪。需要说明的是，成立敲诈勒索罪要求对被害人形成恐惧心理，即要求对被害人形成心理强制，是要求对被害人实施不利行为，实施相应的加害。而本案中，甲并没有以“加害”相威胁，不成立敲诈勒索罪。

D 错误。根据《刑法》第 223 条（串通投标罪）规定：“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。”串通投标罪是破坏社会主义市场经济秩序的犯罪，即破坏了经济秩序，损害了其他竞争者或者招标人的利益。

根据这一规定，构成串通投标罪，必须实施“串通报价”行为，进而损害招标人或者其他投标人利益。本题中，甲根本无意竞买土地使用权，在第三次并无其他公司支付其钱款时，甲便退出竞买。由此看出，甲根本没有实际参与投标，更没有串通投标和串通报价行为，也没有损害招标人或者其他投标人利益，故甲的行为不构成串通投标罪。

综上所述，本题应选 B。

15. 乙用朋友甲的淘宝账户购买一件商品，向商家支付了货款，填写了自己的收件地址。商家发货时，想核对下收件地址，联系到了甲。甲明知是乙购买了货物，仍谎称地址错误，提供了自己的地址。商家将货物寄给了甲。下列说法错误的有？（ ）

- A. 甲对商家构成诈骗罪
- B. 甲对乙构成盗窃罪
- C. 甲构成三角诈骗
- D. 甲构成侵占罪

答案：ACD

解析：

考点：诈骗罪

这种题有个三角关系，犯罪人—债权人—债务人。做题第一步，在债权人和债务人中找

出被害人，也即遭受财产损失的人。对此判断，需要看债务人是否有效履行了债务。如果算是履行了债务，则债务人不是被害人，那么债权人就是被害人。AB 项，第一步，多数观点认为，商家不是被害人，理由是，根据交易规则，名义买家(淘宝账户户主)在地址栏填写收货地址，商家对该地址没有审核义务(审核该地址是不是真正的买家的地址)，淘宝账户户主对收件地址可以随便改。因此，商家依照淘宝账户户主提供的地址发货后便履行了债务，没有财产损失。甲对商家不构成诈骗罪。第二步，乙是被害人，支付了货款，却没收到货，甲在乙不知情的情况下，代为行使了乙对商家的债权，属于盗窃债权，并实现债权，构成侵占罪(既遂)。

C 项，甲对商家不构成三角诈骗，因为三角诈骗要求受骗人处分的是被害人的财物。例如，甲欺骗乙家保姆丙：“我是干洗本的，你的主人让我来取衣服”，而不知情而将乙的表服文给甲，甲构成三角诈骗，本题中，甲欺骗了商家，但商家在发货时，货物属于商家所有并占有。

D 项，甲对商家不构成侵占罪。侵占罪是指将他人所有，自己占有的财物变成自己所有，甲事先并没有占有财物，故不构成侵占罪。

综上所述，本题应选 ACD。

16. 下列选项正确的是？（ ）

A. 甲诈骗被害人钱款到自己账户，乙事后知道并帮甲取现。乙的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪

B. 乙因涉嫌受贿被监察委留置，在留置期间脱逃，乙的行为不构成脱逃罪

C. 甲非法集资 3 亿元，乙明知该款系甲非法集资所得，还帮甲换汇并汇往境外，乙的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪

D. 被执行人甲，以虚假诉讼的方式将财产转移给乙，以逃避执行，甲构成虚假诉讼罪和拒不执行判决罪想象竞合

答案：AD

解析：

考点：侵犯财产罪

A 项，甲的行为构成诈骗罪，乙的行为成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪。乙是在甲犯罪后，事后知情，甲和乙既没有事前通谋，也没有事中帮忙，据此没有共同犯罪的故意，不可能和甲构成诈骗罪的共同犯罪。故 A 选项正确。

B 项，《中华人民共和国监察法》第 44 条第 3 款规定“被留置人员涉嫌犯罪移送司法机关后，被依法判处管制、拘役和有期徒刑的，留置一日折抵管制二日，折抵拘役、有期徒刑一日”。根据这一规定，被采取留置措施的犯罪嫌疑人，实际上是被剥夺了人身自由的，属于被关押的犯罪嫌疑人。其逃跑的，构成脱逃罪。故 B 选项错误。

C 项，乙的行为构成洗钱罪。根据《刑法》第 191 条的规定，洗钱罪的上游犯罪包括金融诈骗犯罪，而本案中的集资诈骗罪亦属于金融诈骗犯罪，故乙的行为构成洗钱罪。当然，洗钱罪是掩饰、隐瞒犯罪所得罪的特别法，适用时应坚持特别法优先，故乙的行为构成洗钱罪。故 C 选项错误。

关于 D 项，2018 年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第 4 条规定：实施《刑法》第三百零七条之一第一款（虚假诉讼）行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成诈骗罪，职务侵占罪，拒不执行判决、裁定罪，贪污罪等犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。故本案构成虚假诉讼罪与拒不执行判决、裁定罪的想象竞合，应择一重罪处罚。故 D 选项正确。

综上所述，本题应选 AD。

17. 某国企公司里，保险柜须由钥匙和密码共同打开，会计刘某掌管钥匙，出纳陈某掌握密码。下列表述正确的是？（ ）

- A. 陈某捡到刘某的钥匙据为己有，并打开保险柜取走财物，属于利用职务便利
- B. 陈某骗取刘某的钥匙据为己有，并打开保险柜取走财物，属于利用职务便利
- C. 刘某和陈某共谋打开保险柜，并取走财物，属于利用职务便利
- D. 刘某偷看陈某的密码，并打开保险柜取走财物，属于利用职务便利

答案：ABCD

解析：

考点：职务侵占罪

行为人对其所在单位是否构成表见代理并不影响对行为人的定罪，行为人编造虚假公司业务，利用职务身份获取被害人信任，骗取被害人财物的行为，依法构成诈骗罪。区别诈骗罪与职务侵占罪的关键在于，前者侵占的是被害人基于错误认识而处分的财产，后者侵占的是行为人保管、经营的单位财产。行为人是否构成表见代理，在民事法律关系中直接影响各方的民事权利义务，但并不影响诈骗罪与职务侵占罪的甄别定性。即使被告人构成表见代理，单位可能承担相应的民事责任，该民事责任的承担也是民事法律规范适用的结果，并非行为人的犯罪行为直接引起，也不是行为人主观故意直接指向的后果。不能因为行为人所在单位最终在民事法律关系中承担了相应责任，进而以该最终后果为标尺认为行为人的侵占对象是单位财产。单位承担民事责任的原因主要是管理责任之必要。只要行为人主观上有非法占有他人财产的故意，客观上实施了“骗”的行为，侵占了被害人财产，而不是利用职务上的便利侵占其自己经营、保管的单位财产，就应当以诈骗罪认定。如果行为人让被害人将资金汇入单位账户，那么资金归单位控制，在这种情况下，行为人利用职务便利占有、处分单位账户里的资金，则属于职务侵占。行为人是否具有代理权以及是否构成表见代理，对于行为人占有、处分被害人所交付的财物，是构成诈骗罪还是职务侵占罪，没有刑法上的意义。

判断行为人占有、处分被害人财物的行为性质，必须看该财产是否处于行为人所在单位占有和控制下。如果是，那么行为人的行为性质属于职务侵占；如果不是，那么行为人的行为性质属于诈骗。

综上所述，本题应选 ABCD。

二、侵犯社会法益犯罪

（一）危害公共安全罪

1. 关于危害公共安全犯罪，下列说法正确的是？（ ）

A. 甲和邻居乙素有嫌隙，某日见乙车停在楼下，见周围没人，往下扔石块致乙车玻璃破碎，甲构成以危险方法危害公共安全罪

B. 甲开煤气自杀，虽没导致燃、爆后果，但仍威胁四周邻居安全。甲构成以危险方法危害公共安全罪

C. 甲醉酒开车在高速公路上超速逆行 10 公里，由于其他车辆避让，没有造成损失。甲不构成以危险方法危害公共安全罪

D. 甲在高速公路泼洒机油，致多车打滑造成严重损失。甲构成破坏交通设施罪

答案：BD

解析：

考点：危害公共安全犯罪

A 错误。甲因和邻居乙有嫌隙，见乙车停在楼下，为报复乙这一特定对象，见周围没人，往下扔石块砸中乙车，致乙车玻璃破碎。该选项中，甲虽然从高空抛下石块，但甲是在确定周围没有人的情况下才实施的行为，可见甲并没有危害公共安全的故意。并且仅仅抛下一个石块，其产生危险的范围有限，危险范围不具有扩张性，并不足以危害公共安全。因此，甲不构成以危险方法危害公共安全罪。甲故意砸碎乙车玻璃的行为构成故意毁坏财物罪。

B 正确。甲开煤气自杀，仍威胁四周邻居安全，虽然没有导致燃、爆后果的，但足以危害公共安全，构成以危险方法危害公共安全罪。以危险方法危害公共安全罪是危险犯，只要行为足以导致危险状态即构成本罪，不需要造成严重后果。造成严重后果的，作为本罪的加重情节。

C 错误。司法实践中，对于驾驶机动车行为，可能涉及危险驾驶罪、交通肇事罪、以危险方法危害公共安全罪三罪。上述三罪的危害性是递增关系，一般认为，车辆驾驶过程中，客观危险性越高、造成危害结果的可能性越大、违章程度越严重，越有理由认为行为人主观罪过程度更重，更应定重罪。

本选项中，甲醉酒开车在高速公路上超速逆行 10 公里，高速公路上通常来往车辆较多，且车速较快，甲醉酒后在高速上超速逆行，且逆行的里程、时间较长，足以危害公共安全，虽由于其他车辆避让，没有造成严重后果，但不影响甲成立以危险方法危害公共安全罪。

D 正确。破坏交通设施罪，是指故意破坏轨道、桥梁、隧道、公路、机场、航道、灯塔、

标志或者进行其他破坏活动，足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生倾覆、毁坏危险的行为。其中的破坏行为包括使交通设施本身遭受毁损和使交通设施丧失应有性能的行为。

本案中，甲在高速公路泼洒机油，使高速公路丧失其为汽车提供安全驾驶环境的性能，导致多车打滑，具有发生车辆倾覆的危险，且造成严重损失，因此甲构成破坏交通设施罪。破坏交通设施罪与以危险方法危害公共安全罪是特别法与一般法的关系，应优先适用特别法，成立破坏交通设施罪。

综上所述，本题应选 BD。

2. 甲卖迷药，明知乙将使用迷药进行犯罪活动，仍然教乙迷药的使用方法等知识，乙用迷药迷倒丙后拿走了丙的财物。后乙多次使用该迷药实施犯罪行为。关于甲乙的行为的定性，下列哪一说法是错误的？（ ）

- A. 甲的行为成立以危险方法危害公共安全罪，因为该行为会导致乙实施不特定的犯罪
- B. 甲的行为不成立以危险方法危害公共安全罪，因为出售迷药的行为不会危害公共安全
- C. 乙的行为成立抢劫罪
- D. 甲的行为成立抢劫罪的帮助犯，亦触犯了传授犯罪方法罪，属于想象竞合

答案：A

解析：

考点：以危险方法危害公共安全罪、共同犯罪

以危险方法危害公共安全罪，是指故意使用放火、决水、爆炸、投放危险物质以外的危险方法危害公共安全的行为，对象是不特定的人，而出售迷药的对象是特定的，因此该行为不会危害公共安全。A 错误。

综上所述，本题应选 A。

3. 关于危害公共安全罪，下列说法错误的是？（ ）（单选）

- A. 虽然实施放火行为，但没有对公共安全造成危险的，不构成以危险方法危害公共安全罪
- B. 在未发生火灾时，只要实施了损坏消防栓等防火工具的行为，就构成以危险方法危害公共安全罪
- C. 在公共场所引爆炸药导致数人重伤，构成爆炸罪和故意伤害罪想象竞合
- D. 刑法特别规定了高空抛物罪，即便高空抛物的行为没有危害公共安全，也构成高空抛物罪

参考答案：B

解析：A、B 项：《刑法》第 114 条规定了放火罪、爆炸罪、决水罪、投放危险物质罪、以危险方法危害公共安全罪。要成立《刑法》第 114 条所规定的犯罪，不仅行为要危害公共安全，而且要以较为严重的行为方式危害公共安全。而对于《刑法》第 114 条所规定的

犯罪，刑法理论上主张对该类犯罪进行限制解释，即对“放火、爆炸、决水、投放危险物质、危险方法”等行为方式进行限制解释，同时，对该类犯罪所要求的“公共安全”也进行限制解释。因此，如果行为根本不可能危害公共安全，也无危害公共安全的可能性，行为就不能认定为放火罪（即没有危害公共安全），也就不能认定为以危险方法危害公共安全罪。

A 选项中，由于放火行为没有危害公共安全，因此不成立放火罪。因此，A 项正确。

B 选项中，如果损坏消防栓的行为没有危害到公共安全，那么就不能构成以危险方法危害公共安全罪。当然，如果在火灾发生之际，行为人损坏消防栓的，直接影响了火灾的扑灭，应认定为以危险方法危害公共安全罪。因此，B 项错误。实践中，部分案件，对于单纯的破坏消防栓的行为（未发生火灾时），认定为以危险方法危害公共安全罪，过于扩张了以危险方法危害公共安全罪的适用范围，值得反思。

（二）破坏社会主义市场经济秩序罪

1. 关于破坏社会主义市场经济秩序罪，正确的是？（ ）

A. 甲在新冠肺炎期间，大量生产、销售不符合国家标准、行业标准的 KN95 防尘口罩，甲构成生产、销售伪劣产品罪

B. 甲明知乙实施金融诈骗行为，仍然协助乙将犯罪所得资金汇往境外，甲构成洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，想象竞合

C. 甲在自己亲友和科室同事之间宣传投资机会，共吸收 20 余名亲友和同事的资金用于投资，并许诺给予高额回报。甲不构成非法吸收公众存款罪

D. 甲为让自己的公司成功上市，虚开增值税专用发票以虚构公司业务量，但并不抵扣税款，甲不构成虚开增值税专用发票罪

答案：ACD

解析：

考点：破坏社会主义市场经济秩序罪

A 正确。《刑法》第 140 条规定，生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额在 5 万元以上的，构成生产、销售伪劣产品罪。

B 错误。甲明知乙实施金融诈骗行为，仍然协助乙将犯罪所得资金汇往境外，甲的行为既构成洗钱罪又构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪属于特别法与一般法的关系，也即触犯洗钱罪的行为也必然构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。因此，甲构成洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪的法条竞合，而不是想象竞合。

C 正确。非法吸收公众存款罪的对象是公众，即社会上不特定的人，不包括自己的亲朋好友。甲仅在自己的亲友与科室同事之间吸收存款，其影响的范围有限，甲的行为不构成非法吸收公众存款罪。

D 正确。刑法将虚开增值税专用发票规定为犯罪，主要是为了惩治那些为自己或为他人

偷逃、骗取国家税款虚开增值税专用发票的行为。对于确有证据证实行为人主观上不具有偷、骗税目的，客观上也不会造成国家税款流失的虚开增值税专用发票行为，不以虚开增值税专用发票犯罪论处，构成其他犯罪的，以其他犯罪定罪处罚。

该选项中，甲虚开增值税专用发票的目的在于虚构公司业务量，其并没有抵扣税款，没有对国家税款流失造成影响，因此，甲不构成虚开增值税专用发票罪。

综上所述，本题应选 ACD。

2. 甲未取得药品批准许可，从境外进口治疗丙型肝炎的药物，转卖给国内患者（该药物在境外是合法药品），获利三十余万元。患者服用药品后，病情均有一定程度好转。关于甲的刑事责任，下列说法正确的是？（ ）（单选）

- A. 非法经营罪
- B. 妨害药品管理罪
- C. 销售假药罪
- D. 不构成犯罪

参考答案：D

解析：A 选项：在《刑法修正案（十一）》增设妨害药品管理罪之前，有许多司法机关已经将甲的行为认定为非法经营罪。但是，在《刑法修正案（十一）》施行之后，对这种行为以非法经营罪论处，就会出现明显的不协调现象。亦即，上述行为“足以危害人体健康”，成立妨害药品管理罪（该罪的入罪标准是“足以危害人体健康”），最高只能处 7 年有期徒刑；不足以危害人体健康的，成立非法经营罪，反而最高可以处 15 年有期徒刑。所以，对于“未取得药品相关批准证明文件生产、进口药品或者明知是上述药品而销售的”行为，如果足以危害人体健康，就以妨害药品管理罪论处；如果不足以危害人体健康，不应以犯罪论处，而不能认定为非法经营罪。再者，非法经营罪是一个口袋罪，应限制适用。在《刑法修正案（十一）》已经规定了更为具体、处罚更轻的妨害药品管理罪之后，就不宜将未经批准经营境外合法药品的行为认定为非法经营罪，而应坚持特别法优先，成立妨害药品管理罪。因此，A 选项错误。

B 选项：《刑法》第 142 条（妨害药品管理罪）规定：“违反药品管理法规，有下列情形之一，足以严重危害人体健康的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”故成立妨害药品管理罪，要求达到“足以严重危害人体健康”这一危险状态。本案中，患者服用甲销售的药品后病情均有一定程度好转，并未对其身体健康造成严重危害。所以，甲的行为不成立妨害药品管理罪。因此，B 选项错误。

C 选项：对于销售假药罪的认定，2021 年《刑法修正案（十一）》将依据《药品管理法》认定假药的条款予以删除，但即便如此，对假药的认定也只能以《药品管理法》的规定为依据，而不意味着刑法上的假药有其他特定含义。2019 年全国人大常委会修订了《药品管理法》，删除了拟制假药（质量合格但程序上不合格的药品）的规定，假药的范围被限缩为“成份不符、以假充真、变质等”质量上不合格的药品。本案中，甲销售的药品仅仅是“程序上

不合格，但质量上合格”，不属于刑法意义上的假药，故甲的行为不成立销售假药罪。因此，C 选项错误。

综上所述，甲的行为不应认定为犯罪，本题答案为 D 项。

3. 甲（A 公司股东）、乙（A 公司总经理）为男女朋友，分手后，甲怀恨在心，经自己研究发现，A 公司生产的保健品毫无保健作用。甲抛售股票后紧接着在网上公布该研究结果，并写明乙是公司总经理。该报告导致 A 公司股价狂跌。关于甲的行为，下列哪一说法是正确的？（ ）

- A. 甲构成破坏生产经营罪
- B. 甲构成侵犯公民个人信息罪
- C. 甲构成内幕交易罪
- D. 不构成犯罪

答案：D

解析：

考点：破坏生产经营罪

A 项，破坏生产经营罪，是指由于泄愤报复或者其他个人目的，毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营的行为。甲公布揭发该上市公司的保健品没有功效是公民的权利，不属于破坏生产经营罪。A 项说法错误。

B 项，“公民个人信息”，是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。公民的任职情况也属于公民个人信息。但是，成立侵犯公民个人信息罪，要求情节严重。甲仅公布了赵某一个人的个人信息，尚不构成情节严重，故不构成侵犯公民个人信息罪。B 项说法错误。

C 项，内幕交易罪，是指证券交易内幕信息的知情人员在涉及股票、证券的发行、交易或者其他对股票、证券的价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该股票、证券，或者泄露该信息，情节严重的行为。第一，成立本罪，要求行为人是“知情人员”。知情人员也称内幕人员，是指由于持有发行人的证券，或者在发行人或者与发行人有密切联系的公司中担任董事、监事、高级管理人员，或者由于其会员地位、管理地位、监督地位和职业地位，或者作为雇员、专业顾问履行职务，能够接触或者获得内幕信息的人员。题中甲只是持有该上市公司股票的股民，不属于内幕信息知情人员。第二，该公司的保健品没有功效，不属于内幕信息。因此，甲不构成内幕交易罪。C 项说法错误。 综上所述，本题应选 D。

4. 下列关于走私的认定，正确的是？（ ）

A. 关某不清楚法律是否允许公民携带黄金出境，出国时悄悄把随身佩戴的黄金佛像（500 克）放入行李箱，关某不构成走私贵重金属罪

- B. 赵某携带假币，驾船至公海寻找买家未果，只好返回原地，赵某构成走私假币罪
- C. 吴某从境外购买枪支，但收到对方从境外快递来的军用子弹，吴某构成走私枪支罪
- D. 钱某以传播为目的，在国内浏览境外网站，下载大量淫秽视频，还给朋友看。钱某构成走私淫秽物品罪

答案：B

解析：

考点：走私罪

A 错误。根据《中华人民共和国海关限制进出境物品表》，金银等贵金属及其制品属于限制出境物品，出境旅客携带黄金 50 克以下的，海关予以放行。重量超过 50 克的，海关凭中国人民银行出具的批准证明查验放行。不能提供证明，不予放行。因此，关某的数量超过 50 克，可以认定为是走私。

B 正确。赵某构成走私假币罪。客观上，赵某实施了携带假币进入公海又返回的走私行为。赵某明知是假币，仍实施了携带假币赵入公海的行为，主观上具有走私的故意。因此，赵某成立走私假币罪。

C 错误。吴某从境外购买枪支，但收到对方从境外快递来的军用子弹，吴某主观上具有走私枪支的故意，客观上实施了相应的行为，虽然走私的对象实际上是军用子弹，但军用子弹也具有武器、弹药的属性，也属于走私武器、弹药罪的犯罪对象，属于同一构成要件内的错误，故可以认定吴某构成走私弹药罪。

D 错误。钱某的行为不构成走私淫秽物品罪。首先，走私淫秽物品中的“以传播为目的”，是指走私淫秽物品是为了在社会上传播、扩散，本题中，尽管钱某下载了大量淫秽视频，但其仅仅是给朋友看，并没有在社会上进行传播、扩散，据此，钱某虽然有故意的责任要素，但并不具备以传播为目的。

其次，走私淫秽物品要违反海关法规，逃避海关监管，根据一般社会观念，浏览境外网站(俗称“翻墙”)并不违法，我国现有的有关网络信息法律中也并未有专门针对“翻墙”的相关法条，因此，客观上，钱某浏览境外网站行为不属于走私行为，其行为并没有违反海关法规，故，钱某的行为不构成走私淫秽物品罪。

综上所述，本题应选 B。

5. 关于走私犯罪，下列说法正确的有？（ ）

- A. 王某以传播为目的，在家中登录境外网站，下载淫秽影片，发给几位朋友观看，构成走私淫秽物品罪
- B. 陈某向境外网站购买枪支，邮寄到境内陈某家中，陈某构成走私武器罪
- C. 张某不知道法律是否允许，将贴身佩戴的小金佛吊坠放在行李里带出国，构成走私贵重金属罪
- D. 李某携带假币前往公海出售，没有卖掉，又带回境内，构成走私假币罪

答案：BD

解析：

考点：走私犯罪

A 项，走私淫秽物品罪，是指违反海关法规，逃避海关监管，以牟利或者传播为目的，非法运输、携带、邮寄淫秽物品进出境的行为。王某在家中登录境外网站，下载淫秽影片。此时境外网站的注册地虽然在境外，但是下载行为发生在国内，因此不属于将淫秽物品从国外携带至国内，也即不属于进出境的行为，因此不属于走私行为。并且，王某只给少数几位朋友观看，也不属于传播淫秽物品罪。后者要求传播给不特定人或多数人。

B 项，陈某从境外购买枪支，邮寄到国内，构成走私武器罪。

C 项，走私贵金属罪是故意犯罪，要求明知该金属属于国家禁止出境的贵金属。由于张某对此并不明知，因此不构成走私贵金属罪。

D 项，走私假币罪，是指违反海关法规，逃避海关监管，非法运输、携带假币进出境的行为。李某携带假币从境内进入公海，表明已经出境，构成走私假币罪。李某将假币从公海带进境内，再次构成走私假币罪。不过由于这两次行为具有连续性，可以以一罪处理。

综上所述，本题应选 BD。

6. 市面上销售一款奶粉，甲购买后倒出一部分，掺入植脂末（又称奶精，是一种食品添加剂，但大量添加对人体有害），然后仍以该产品商标进行销售。后查明该奶粉不符合食品安全标准，足以造成严重食物中毒事故。被查出时，奶粉的货值金额达到 20 万元，但还没有出售获利。下列说法正确的是？（ ）（多选）

- A. 甲构成诈骗罪既遂
- B. 甲构成假冒注册商标罪既遂
- C. 甲构成销售假冒注册商标的商品罪既遂
- D. 甲构成生产不符合安全标准的食品罪既遂

参考答案：B，D

解析：A 项：诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，甲虽然意图将不符合安全标准的奶粉冒充合格产品销售给他人，但尚未出售获利，顾客没有因此遭受财产损失。因此，甲的行为不构成诈骗罪既遂。退一步讲，即使认为销售不符合安全标准的食品罪或销售假冒注册商标的商品罪与诈骗罪之间可能存在竞合，并认为这是想象竞合，因而有可能认定为诈骗罪。但成立诈骗罪的既遂是要求造成被害人的损失，被害人基于错误认识而处分财产，本案中，被害人（购买者）并没有基于错误认识而处分财产，故不宜认定为是诈骗罪既遂。因此，A 项错误。

B 项：首先，甲的行为构成假冒注册商标罪。行为人将报废的商品重新组装后，打算按照原商标进行出售的，依然成立假冒注册商标罪。在本案中，甲将掺有植脂末的奶粉重新封装后，依然打算按照原商标进行出售，即使还未销售，也构成假冒注册商标罪。当然，如果

甲已经将上述假冒注册商标的商品出售的，成立销售假冒注册商标的商品罪。其次，甲的行为属于“情节严重”。成立假冒注册商标罪，要求具有严重情节。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，假冒注册商标的违法所得数额在三万元以上或者非法经营数额在五万元以上的，即达到情节严重的标准。该解释第十二条规定，“非法经营数额”，是指行为人在实施侵犯知识产权行为过程中，制造、储存、运输、销售侵权产品的价值。未销售的侵权产品的价值，按照标价或者已经查清的侵权产品的实际销售平均价格计算。在本案中，甲虽然没有售出假冒商标的奶粉，但其货值金额达到了 20 万元，属于情节严重。因此，甲成立假冒注册商标罪。因此，B 项正确。

C 项：首先，甲成立销售假冒注册商标的商品罪。销售假冒注册商标的商品罪，是指明知是假冒注册商标的商品，仍然予以出售，违法所得数额较大或者有其他严重情节的行为。本案中，甲明知该奶粉是假冒注册商标的奶粉，仍然打算予以出售的，构成销售假冒注册商标的商品罪。

其次，甲的行为成立销售假冒注册商标的商品罪的未遂。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条规定，假冒注册商标的商品尚未销售，货值金额在十五万元以上的，以销售假冒注册商标的商品罪的未遂论处。在本案中，甲尚未销售假冒注册商标的商品，但货值金额达到 15 万元以上，成立销售假冒注册商标的商品罪的未遂。因此，C 项错误。

D 项：首先，甲的行为成立生产不符合安全标准的食品罪。生产、销售不符合安全标准的食品罪，是指生产、销售不符合食品安全标准的食品，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的行為。本案中，甲向奶粉中掺入植脂末，足以造成严重食物中毒事故。因此，甲的行为成立生产不符合安全标准的食品罪。其次，甲的行为足以造成严重食物中毒事故，具有使不特定多数人食物中毒的危险，且生产行为已经完成，成立犯罪既遂。因此，甲的行为构成生产不符合安全标准的食品罪。因此，D 项正确。

综上所述，本题答案为 BD 项。

（三）妨害社会管理秩序罪

1. 关于帮助信息网络犯罪活动罪及相关犯罪的认定，下列选项说法正确的是？（ ）
（单选）

A. 甲明知肖某使用银行卡用于电信诈骗而提供银行卡，肖某也用于电信诈骗的，甲的行为仅成立帮助信息网络犯罪活动罪

B. 乙以为徐某使用银行卡用于开设网络赌场而提供银行卡，但是无法查清徐某是否用于犯罪，乙的行为成立帮助信息网络犯罪活动罪

C. 丙以为蒋某使用银行卡用于网络赌场而提供银行卡，但是蒋某用于电信诈骗的，丙的行为成立诈骗罪的帮助犯

D. 丁以为陈某使用银行卡要用于电信诈骗而提供银行卡，但是陈某并未实施犯罪的，丁的行为不成立犯罪

参考答案：D

解析：A 项：首先，本案中，甲明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行卡的，甲的行为应成立帮助信息网络犯罪活动罪。其次，对于甲的行为是否成立诈骗罪，有的同学可能存在疑问，认为既然立法已经规定了帮助信息网络犯罪活动罪，为什么还构成诈骗罪呢？但是，甲为肖某电信诈骗提供了帮助（提供银行卡），直接造成了法益侵害结果，应肯定甲的行为与该结果之间具有物理的因果性，认定为诈骗罪的共犯，与成立帮助信息网络犯罪活动罪并不矛盾。或许有同学认为甲只是提供信用卡，并没有对肖某有后续的帮助行为。这是否对成立诈骗罪的共犯存在影响？一般认为，提供银行卡给对方，绝大部分人是知道对方要用银行卡进行电信诈骗的，明知对方利用银行卡进行电信诈骗，这里的明知只要预见或者说知道对方可能利用银行卡实施电信诈骗即可，在这样的情形下，即具备通常所说的诈骗罪共犯的故意。后续只要查明对方确实用银行卡实施了诈骗犯罪，供卡者和诈骗正犯之间怎么联系，有没有联系都不影响诈骗罪共犯的认定。综上，甲的行为除了成立帮助信息网络犯罪活动罪外，还与诈骗罪存在竞合，应当择一重罪处罚，认定为诈骗罪的帮助犯。因此，A 项错误。

B 项：如果根本查不清楚对方使用银行卡实施了什么行为，则无法认定共犯，也无法认定帮助信息网络犯罪活动罪，因为认定帮助信息网络犯罪活动罪，也至少要查明对方利用电信网络实施了犯罪。因此，B 项错误。可以认为，如果明知他人实施具体的犯罪（如诈骗罪、开设赌场罪等）而提供银行卡的，构成具体犯罪的共同犯罪。但如果只是抽象地知道他人要去实施信息网络犯罪，而不知道具体的犯罪的，且后续他人确实实施了相关犯罪，构成帮助信息网络犯罪活动罪。

C 项：本案中，丙以为对方是要开设网络赌场，结果把卡给对方之后，对方实施了电信诈骗，此种情形丙不具备诈骗罪共犯的故意，不能成立诈骗罪的共犯。如前所述，丙明知他人要实施信息网络犯罪活动，而且他人确实实施的也是信息网络犯罪活动，因此，在“信息网络犯罪”这一问题上，丙的主观认识与客观是一致的，故丙的行为成立帮助信息网络犯罪活动罪。因此，C 项错误。

D 项：丁的行为不成立犯罪。一方面，丁没有实施任何不法侵害行为。另一方面，丁提供银行卡本身的行为不可能侵犯任何法益。所以，对于丁的行为不可能以犯罪论处。《刑法》虽然将帮助他人实施信息网络犯罪的行为规定为独立的罪名（帮助信息网络犯罪活动罪），对于该罪的认定，亦应该贯彻共犯从属性理论，这是帮助行为“相对正犯化”。只有被帮助者实施了相应的犯罪，帮助者才能认定为犯罪（帮助信息网络犯罪活动罪）。本案中，被帮助者陈某并没有实施犯罪，故丁的行为不构成犯罪。需要说明的是，《刑法》对于部分帮助

行为、预备行为规定为独立的罪名，是预备行为、帮助行为绝对正犯化，只要实施了帮助行为，即使被帮助者没有实施具体的犯罪行为，对帮助者也应该以犯罪论处。这主要是针对较为严重的犯罪的帮助行为，例如，《刑法》第 107 条（资助危害国家安全犯罪活动罪）将帮助行为（资助）正犯化，规定为独立的罪名，只要实施了资助行为的，不再作为帮助犯（共犯）论处，而是作为独立的罪名，即资助危害国家安全犯罪活动罪。丁资助林某从事危害国家安全的犯罪活动，但林某尚未实施相关犯罪活动即被抓获。丁属于资助危害国家安全犯罪活动罪（既遂）【2016 年第 2 卷第 53 题 D 项】因此，D 项正确。

综上所述，本题答案为 D 项。

2. 关于黑社会性质组织犯罪, 下列哪一说法是正确的? ()

A. 甲是某有组织犯罪的首要分子, 该组织成立两年后甲中途离开, 甲不需要对其离开后该组织实施的犯罪行为负责

B. 对黑社会性质组织的首要犯罪分子的处罚一定比其他成员的处罚要重

C. 对黑社会性质组织的首要分子的处罚一定比实行者要重

D. 具有保护伞不是认定黑社会性质组织的必备条件

答案: D

解析:

考点: 黑社会性质的组织犯罪

A 错误。首要分子是组织、领导者，是创始人，即便其中途“退出”，也需要对后续他人的犯罪行为承担责任。因为其成立一个组织，为他人的犯罪提供了组织，搭建了平台，即便中途退出，也没有消除其影响力。

B、C 均错误。最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第 30 条：明确了黑社会性质组织中不同成员的处理原则：分别情况，区别对待。对于组织者、领导者应依法从严惩处，其承担责任的犯罪不限于自己组织、策划、指挥和实施的犯罪，而应对组织所犯的全部罪行承担责任。

D 正确。根据刑法规定，保护伞只是认定黑社会性质组织的选择要件，而不是必备要件。

综上所述，本题应选 D。

3. 甲、乙两个人要去开歌舞厅，乙提议在歌舞厅中进行淫秽表演。甲的父亲认可并表示可以提供帮助，但要求如果以后事发，乙不能把甲给供出来。乙的父亲知道后表示赞同，但未提供任何帮助。后事发，乙因此被公安机关抓获后未供出甲，乙的父亲也未供出甲。下列说法错误的是? () (多选)

A. 甲的父亲构成包庇罪

B. 甲的父亲构成妨害作证罪

B. 乙的父亲构成包庇罪

C. 乙的父亲构成伪证罪

参考答案: A, B, C, D

解析：A 项：窝藏、包庇行为是在被窝藏、包庇的人犯罪后实施的，其犯罪故意也是在他人犯罪后产生的，即只有在与犯罪人（本犯）没有事前通谋的情况下（不构成共同犯罪），实施窝藏、包庇行为的，才成立窝藏、包庇罪。本案中，甲的父亲在甲、乙开展淫秽表演前就已经知道此事，并且表示可以提供帮助，属于事前通谋，应当成立共同犯罪。因此，甲的父亲不构成包庇罪，A 项错误。

B 项：如前所述，甲的父亲与甲、乙已经成立共同犯罪。共同犯罪人本人，就其共同犯罪的事实，妨害他人作证的，系事后不可罚行为，不应以妨害作证罪论处。本案中，甲的父亲作为共犯，其劝说他人不要作证的行为，不成立妨害作证罪。因此，B 项错误。

C 项：明知发生犯罪事实或者明知犯罪人的去向，而不主动向公安、司法机关举报的行为，属于单纯的知情不举行为，不成立窝藏、包庇罪。知道犯罪事实，在公安、司法机关调查取证时，单纯不提供证言的，也不构成窝藏、包庇罪。换言之，包括窝藏、包庇罪在内的妨害司法类的犯罪，原则上都是积极的行为，单纯的知情不举，原则上不构成犯罪。本案中，乙的父亲知道甲与乙的犯罪事实，但是单纯未提供证言，不成立包庇罪。因此，C 项错误。

D 项：伪证罪，是指在刑事诉讼中，证人、鉴定人、记录人、翻译人对案件有重要关系的情节，故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的行为。其中，行为人必须作了虚假的证明，必须是积极的行为，单纯的知情不举，不构成伪证罪。本案中，乙的父亲仅是未供出甲，并未做虚假陈述，不构成伪证罪。因此，D 项错误。

综上所述，本题答案为 ABCD 项。

4. 关于窝藏罪，下列说法正确的是？（ ）（多选）

A. 甲犯罪后不想逃跑，甲的妻子在甲的食物中投放安眠药，趁甲睡着，带甲去外地暂时躲避。甲的妻子不构成窝藏罪

B. 乙犯罪后，原本不想逃跑，甲劝说乙逃跑，后乙经甲劝说后逃跑。甲不构成窝藏罪

C. 丙犯罪后逃匿，在逃跑期间打电话拜托徐某照顾自己的妻子。在丙外逃期间，徐某一直给丙的妻子打生活费，使丙在外面得以安心。徐某不构成窝藏罪

D. 丁犯罪后，在外逃匿期间，其妻子相随，长年照顾丁的生活起居。丁的妻子不构成窝藏罪

参考答案：A，C，D

解析：A 项：窝藏罪，是指明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿的行为。其中，“帮助”不是共犯意义上的帮助，即使犯罪人没有打算逃匿，也没有逃匿行为，但行为人使犯罪人昏迷后将其送至外地的，或者“劝诱”“迫使”犯罪人逃匿的，也属于“帮助其逃匿”。从这一意义上看，甲的妻子行为成立窝藏罪。但是，犯罪人的配偶、近亲属对犯罪人实施的窝藏、包庇行为，由于缺乏期待可能性，不宜认定为窝藏罪，这也符合中国传统文化中的“亲亲相隐”原则。或者说，这是基于人的本能所实施的行为，不宜以犯罪论

处。本案中，将甲迷晕带往外地的行为妨害了司法机关发现甲，一般认为应当成立窝藏罪。但是，甲的妻子将其带走，由于缺乏期待可能性，应当认为不构成窝藏罪。因此，A 项正确。

B 项：如 A 选项所述，张明楷教授指出，劝诱犯罪人逃匿的，成立窝藏罪。这是一种相对积极的行为，使本来未逃匿的人逃匿了，应属于窝藏罪所要求的“帮助”行为。因此，B 错误。

C、D 项：“帮助其逃匿”中的帮助行为也不应当认定得过于宽泛，应限于直接使犯罪人的逃匿更容易的行为。C 选项中，虽然徐某给丙的妻子打生活费的行为，使得丙在外逃匿期间得以更为“安心”，客观上确实帮助了丙的逃匿。但是，给任何犯罪嫌疑人的妻子打生活费的行为，也是一种关怀行为，这种行为是刑法所允许的，即使创设了风险（丙更愿意外逃），这种风险也是刑法所允许的风险，不宜以犯罪论处。D 选项：如 C 选项解析所述，对窝藏罪应限制解析，否则只要有关联的行为都认定为窝藏罪，会导致刑法过度干预人们的日常生活。“帮助其逃匿”就限于直接使犯罪人的逃匿更为容易的行为，而不是漫无边际的帮助行为。配偶等单纯陪同犯罪人潜逃并且在外地共同生活的，也不应认定为窝藏罪。类似的，犯罪人意欲自首，劝诱其不自首的，不成立窝藏罪。故 D 正确。

因此，C、D 项正确。注意：B 选项和 C、D 选项的区别在于，B 项中，实施了“帮助逃匿”的行为，使本无逃匿想法的人，产生了逃匿的想法和行为。而 C、D 中的犯罪人丙、丁犯罪后，已经有了逃匿的想法和行为，徐某、丁的妻子，只是实施了一般的日常生活行为，并没有提升丙、丁逃匿的故意。与之类似的道理是，张明楷教授指出，毛毛犯罪之后，准备去自首，徐某劝说其不要去自首，徐某的行为并没有帮助毛毛“逃”，因此，也不宜认定为是窝藏罪。

综上所述，本案答案为 ACD 项。

5. 甲卖海洛因 50 克，运输甲基苯丙胺 30 克，走私鸦片 500 克，下列不正确的是？

()

- A. 甲应认定为走私、贩卖、运输毒品罪，不需并罚
- B. 在量刑时，应将鸦片按比例折算成海洛因或者甲基苯丙胺
- C. 不管是否进行折算，均按 580 克毒品总数追究刑事责任
- D. 即使甲被判处 10 年以上有期徒刑或者无期徒刑，满足假释条件的依旧可以假释

答案：C

解析：

考点：毒品犯罪

C 选项，计算不同的毒品数量要先进行折算再计算，不能对不同种类的毒品数量简单相加。C 错误。

综上所述，本题应选 C。

6. 有关毒品犯罪的下列哪些选项是正确的？（ ）

- A. 甲想戒毒，不想吸毒了，便把自己所有的毒品给了乙，刚刚交到乙手上就被警察发现，甲构成非法持有毒品的共犯
- B. 甲从卖家乙处网购少量毒品用于吸食，待甲付款后，乙将毒品运往甲的住处。甲构成运输毒品罪的共犯
- C. 甲贩卖毒品给乙，交付完毕后当场被警察抓获。甲构成贩卖毒品罪，乙构成非法持有毒品罪
- D. 甲毒瘾发作，找毒贩乙购买毒品，毒贩乙嫌麻烦不愿起床遂拒绝出卖毒品。后甲苦苦哀求至毒贩乙同意，乙遂将毒品卖给甲。甲构成贩卖毒品罪的教唆犯

答案：AC

解析：

考点：毒品犯罪

A 正确。甲将毒品交给乙，乙接受毒品，乙具有持有毒品的故意，同时具有“持有”毒品的行为，虽然毒品刚交到乙手上就被警察发现，但乙仍成立非法持有毒品罪。本案中，乙已经持有毒品，虽是短暂的持有，也应该成立非法持有毒品罪（既遂）。甲将毒品交给乙，引起了乙持有毒品的犯罪故意，成立非法持有毒品罪的教唆犯，即成立非法持有毒品罪的共犯。

B 错误。运输毒品罪是重罪，运输毒品罪中的“运输”应作限制解释，只有与走私、贩卖、制造具有关联的运输行为，才宜认定为运输毒品罪。行为人仅仅是购买毒品供自己吸食，从购买地带到目的地的，不属于运输毒品。本案中，乙因贩卖而运输毒品，构成贩卖、运输毒品罪。但甲仅仅是为吸食而购买、运输毒品，不构成运输毒品罪。再者，吸毒本身在我国刑法中是不构成犯罪的，那么维持吸毒所必要的行为，如购买并运输毒品回家，就不宜认定为是犯罪。

C 正确。甲贩卖毒品给乙，并且交付完毕，甲既有贩卖毒品的故意又具有贩卖毒品的行为，同时甲还持有毒品，但贩卖毒品必然持有毒品，因此，贩卖毒品罪可以吸收非法持有毒品罪，甲构成贩卖毒品罪。此外，甲的行为还是犯罪既遂。乙购买毒品不成立犯罪，“购买”行为不是“贩卖”行为，乙的行为不构成贩卖毒品罪。但是，乙后续持有毒品（不考虑数额）的行为，成立非法持有毒品罪。

D 错误。乙本来就是毒品贩卖者，一直具有毒品贩卖的故意，而并非是甲的苦苦哀求行为引起，甲的行为至多只能说是加强了乙此次贩卖毒品的犯意。因此，不成立贩卖毒品罪的教唆犯。教唆犯是将无犯罪意图的人，教唆至有犯罪意图。

综上所述，本题应选 AC。

三、侵犯国家法益犯罪

（一）贪污受贿罪

1. 陈某欲得到一工程，送给非国家工作人员的刘甲 100 万元，希望其能够向管理工程的

副市长刘乙（刘甲胞弟）说情，刘甲将 100 万元现金以及陈某的请求告诉刘乙，刘乙说：“钱你留着，工程我会帮助的。”之后，陈某获得工程。关于本案下列正确的是？（ ）

- A. 刘甲和刘乙构成受贿罪的共同犯罪，陈某构成行贿罪
- B. 刘甲构成利用影响力受贿罪，刘乙构成受贿罪，陈某构成对有影响力的人行贿罪
- C. 刘甲构成利用影响力受贿罪，刘乙不构成受贿罪，陈某构成对有影响力的人行贿罪
- D. 刘甲构成受贿罪，刘乙不构成受贿罪，陈某构成行贿罪

答案：A

解析：

考点：行贿罪、受贿罪

首先，受贿罪的本质在于“权钱交易”。国家工作人员刘乙，明知陈某送给其哥哥刘甲的 100 万元，是其职权行为的对价，仍然不反对，说明其认可了权钱交易，构成受贿罪。刘甲与刘乙构成受贿罪的共犯。国家工作人员的近亲属、特定关系人收受他人财物，国家工作人员事后知情，如果不反对，说明其认可该财物，会给行贿人传递出“权钱交易”的信号，应认定为受贿罪。2016 年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第 16 条规定：特定关系人索取、收受他人财物，国家工作人员知道后未退还或者上交的，应当认定国家工作人员具有受贿故意。

其次，陈某虽然是给刘甲（非国家工作人员，有影响力的人）行贿，但其行贿的目的也是想收买国家工作人员的职权。但其主观上并不明知国家工作人员刘乙有受贿的故意，也就是说，其主观上并没有将财物交给国家工作人员的故意，也不明知国家工作人员刘乙会让刘甲收受 100 万元，故陈某的行为不构成行贿罪。故 A 当选。

综上所述，本题应选 A。

2. 甲为承包工程，意图贿赂官员乙，苦于不认识乙。甲找到乙妻丙，并谎称已与乙达成共识，让丙把钱交给乙，丙信以为真，收钱后告诉乙此事，被乙训斥并责令退还。丙假意答应，实则将钱用于自己消费。下列哪一项是正确的？（ ）

- A. 甲构成对非国家工作人员行贿罪 B. 甲构成行贿罪未遂
- C. 丙构成受贿罪未遂 D. 丙构成利用影响力受贿罪

答案：B

解析：

考点：受贿罪

A 错误。该题中，丙只是国家工作人员的妻子，没有职务，也即不具有利用职务便利为行贿人谋取不正当利益的能力。并且根据题干，甲让丙把钱交给乙，说明甲真正想要行贿的对象是乙而非丙。因此，甲不构成对非国家工作人员行贿罪。

B 正确。甲让丙把钱交给乙，说明甲真正想要行贿的对象是乙，甲为谋取不正当利益，

通过丙给予国家工作人员乙钱财，构成行贿罪。但由于乙拒绝接受，属于意志以外的因素导致行贿未完成，因而甲成立行贿罪未遂。

C 错误。首先，受贿罪属于身份犯，只有国家工作人员才能成立受贿罪。丙并非国家工作人员，因此丙不构成受贿罪。

其次，丙也不构成受贿罪的共犯。丙将收甲钱的事告诉乙后，乙明确拒绝，并责令丙将钱款退还至甲。既然乙不构成受贿罪，那么，丙也不构成受贿罪的共犯。最后，丙明知乙拒绝受贿，仍假意答应，将钱用于自己消费，构成侵占罪，而非受贿罪。

D 错误。本案中给丙一开始是因为受到甲的欺骗而收受甲的财物，甲欺骗丙说“谎称已与乙达成共识，让丙把钱交给乙”，丙并无利用其作为国家工作人员乙的妻子的影响力而收受财物的故意。再者，丙将收甲钱的事告诉乙后，乙明确拒绝，说明丙并没有影响到乙，没有促成权钱交易。因此，丙不构成利用影响力受贿罪。

综上所述，本题应选 B。

3. 村民甲为了多获土地补偿款，找到负责核定土地面积的国家机关工作人员乙，让其核定面积时多写面积，并且送了 10 万元感谢费给乙。乙答应照办，甲因此多获了 40 万元的土地补偿款。下列说法正确的是？（ ）

- A. 甲、乙二人成立贪污罪的共犯，贪污的金额为 40 万元
- B. 甲送给乙 10 万元构成行贿罪
- C. 乙收受甲提供的 10 万元，构成受贿罪
- D. 甲送给乙行贿的 10 万元，不应从其贪污的 40 万元补偿款中扣除

答案：ABCD

考点：贪污贿赂罪

B 项，甲向乙送十万元，构成行贿罪既遂。乙构成受贿罪既遂。BC 项说法正确。A 项，贪污罪要求有非法占有目的。该非法占有目的既包括为自己非法占有，也包括为第三人非法占有。乙如果将土地补偿款据为己有，无疑构成贪污罪。乙将土地补偿款处分给甲，让甲占有，属于为第三人非法占有，也构成贪污罪。乙是贪污罪的实行犯，甲没有国家工作人员的身份，仅构成贪污罪的教唆犯。二人构成贪污罪的共同犯罪，数额是 40 万元。D 项，乙的收钱行为构成受贿罪，乙的处分土地补偿款的行为构成贪污罪。这是两个独立行为分别构成两个独立罪名，因此应当数罪并罚。D 项说法正确。

综上所述，本题应选 ABCD。

4. 甲向国家工作人员乙行贿 100 万元，将随取随用的银行卡（户名为甲）交给乙，乙收下。次日，为了帮助银行朋友完成业绩，甲通过网上银行，将银行卡内的 100 万资金转为定期，需要甲领身份证才能使用。案发时，定期存款未到期。下列分析正确的是？（ ）

（单选）（张益铭）

- A. 乙构成受贿罪未遂 B. 甲构成行贿罪既遂
- C. 甲将给予乙的 100 万资金转为定期存款，构成诈骗罪
- D. 甲把乙控制的钱存成定期，构成盗窃罪

参考答案：B

解析：A 项：收受银行卡型的受贿罪，既、未遂的判断标准在于行为人是否可以实际支配该卡内的余额。虽然银行卡的“名义人”是行贿人，但受贿人（国家工作人员）的职权决定了其对银行卡有实质上的掌握权。因此，成立受贿罪既遂。并且，行贿、受贿罪的犯罪既遂的认定时间，应以行贿、受贿行为时（权钱交易时）为准。当乙接受了甲送来的银行卡，就已经构成了受贿罪既遂。周光权教授也认为，如果行贿人已经将银行卡交给受贿人的，即使事后行贿人将银行卡挂失的，由于在转移银行卡时行贿人与受贿人已经就银行卡内的资金归属达成了合意，因此后续行为不妨害成立受贿罪的既遂。在本案中，甲将银行卡交给乙时，银行卡处于随取随用的状态，因此乙对银行卡具有实际上的控制权。因此，乙成立受贿罪既遂，A 项错误。历年真题中考察过该知识点。2022 年公法卷第 31 题：国家工作人员乙收到蒋某送来的银行卡且知道银行卡密码，能够随取随用，构成受贿罪既遂。

B 项：行贿罪的既遂，以国家工作人员客观上接收（占有）了财物之时为准，即便国家工作人员事后退回财物或者及时上交，也不影响行贿罪既遂。本案中，乙已经收下银行卡，事实上占有了财物，因此，甲构成行贿罪的既遂。B 项正确。

C 项：成立诈骗罪，要求被害人因受骗而处分自己的财产。在本案中，甲虽然通过将卡内资金改为定期，使乙无法取出从而欺骗了乙，但乙并未因甲的欺骗行为而处分自己的财产。因此，甲的行为不成立诈骗罪。C 项错误。

D 项：周光权教授认为，因为刑法只是将受贿人“视为”卡内资金的占有人，卡内资金事实上仍然由行贿人占有。因此，行贿人处分卡内资金的，不能够成立盗窃罪。退一步讲，即便将受贿者乙视为卡内资金的占有人，甲并没有非法占有该财物，只是改变了财物的占有方式，并没有非法占有目的，也不能成立盗窃罪。类似的道理如，毛毛的自行车停在楼下，徐某将该自行车暂时（一定时间）扣上了自己的钥匙，徐某的行为也不成立盗窃罪。或者，徐某将毛毛家的门锁换成自己的锁（一定时间），也不成立盗窃罪。在本案中，甲能够将卡内资金转为定期，说明其能够支配该财物，是事实上财物的占有人。因此，甲处分自己占有的财物，该行为不能成立盗窃罪。D 错误。

综上所述，本题答案为 B 项。

【延伸阅读】

对于甲的行为定性，还有一种观点认为，甲的行为成立盗窃罪。例如，曲新久教授认为，受贿人收受银行卡后，行贿人采取挂失或者使用密码、验证码等方式支取（占有）该款项，进而排除受贿人使用银行卡（包括银行卡信息等）支配、控制卡内资金之可能性的，行贿人

构成盗窃罪。理由在于，尽管行贿人在法律规范层面上仍然是持卡人，有权支配、控制卡内资金，但是行贿人事实上看到银行卡内资金转由受贿人占有。行贿人行贿后取回卡内资金，是以非法占有为目的转移（类似于移动有形物）银行卡内款项，应当以盗窃罪论。或者可以认为，行贿人起初将活期银行卡交给受贿人，让渡了该卡内存款的占有权、所有权，但是，后续又给卡内存款调整为定期且需要用行贿人的身份证才可以取出存款，事实上是剥夺了受贿人对已经占有、控制的款项的支配权，破坏了占有关系，应以盗窃罪论处。

【延伸阅读】

关于本案中乙的犯罪形态，也有观点认为乙成立受贿罪的未遂。如最高人民法院刑二庭三级高级法官段凰认为，银行卡的交付并不意味着卡内资金实现了彻底的转让，但是根据受贿人手中拥有职权这一筹码，推断出行贿人通常不会再动用自己作为银行卡登记人冻结、挂失、转移的权利，但这毕竟只是基于社会生活经验常理的一种推断，换言之，认定受贿人拿到银行卡时受贿行为就已经既遂是一种法律拟制的完成，当出现相反的事实时，应当尊重客观事实进行认定。即如果出现行贿人交付银行卡后又更改密码的情形，应当认定受贿人因为意志以外的原因不能取得财物，属于犯罪未遂。在本案中，乙虽然收下了甲的银行卡，但是乙事实上无法使用该银行卡，未能取出财物。因此，乙成立受贿罪的未遂。实务中也有支持受贿罪未遂的观点，认为行贿人贿送银行卡和存单时告知密码，后自行挂失存单及银行卡并改密，构成受贿罪未遂。被告人卢某某任某广播电视台台长期间，电台职工王某某为使其女儿到该单位工作，分别于 2009 年 5 月 15 日、2010 年 1 月某日到被告人卢范生办公室，先后送给卢某某 30000 元存单一张及 30000 元银行卡一张，并将密码告知卢某某。卢范生表示愿意帮忙，并收下存单及银行卡。2010 年 3 月 28 日，王某某认为卢范生不能为其帮忙，遂将上述存单及银行卡挂失并更改账户密码。法院最终认定被告人卢某某受贿王某某 60000 元存单和银行卡，因王某某已将存单和银行卡挂失，应认定为犯罪未遂。法考与实务做法的不一致在于：法考更强调规范的合理性，之前收受没有密码的银行卡，已经构成了既遂，事后也不可能成立未遂或中止。

5. 关于贪污贿赂罪，下列说法正确的是？（ ）（单选）

A. 张某是律师，在 B 区执业。请 A 区法院院长甲帮忙介绍 B 区的案源，甲让 B 区法院院长乙给张某介绍了案源，后张某分别给甲、乙一笔好处费。甲构成受贿罪（斡旋受贿）

B. 甲为谋取不正当利益，想找市长帮忙，给市长的儿子乙送礼。乙将甲的诉求转达给父亲（市长），但市长不同意帮忙。乙构成利用影响力受贿罪的既遂

C. 甲为谋取不正当利益，想找市长帮忙，给市长的儿子乙送礼。但乙还未向市长说明任何情况，市长主动为甲谋取了不正当利益。一周后，市长从乙口中得知乙收受了甲的礼物，也未反对。乙构成利用影响力受贿罪的既遂

D. 甲为谋取不正当利益，想找市长帮忙，给市长的儿子乙送礼。乙未收下礼物，但是答

应为甲帮忙。乙向市长说明后，市长同意帮忙。乙构成利用影响力受贿罪的既遂

参考答案：A

解析：A 项：受贿罪的表现形式之一“斡旋受贿”，是指国家工作人员利用本人职权或者地位形成的“便利条件”，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的行为。换言之，与其他类型的受贿罪不同的是，斡旋型受贿中，受贿者并没有直接的职务上的便利（说了不算），要通过其他国家工作人员的权力（说了算）。在本案中，A 区法院院长并非通过职权为张某介绍案源，而是利用工作关系拜托了 B 区法院院长。因此，甲的行为成立“斡旋型”受贿罪。因此，A 项正确。

B 项：利用影响力受贿罪的保护法益包括工作人员职务行为的公正性，以及国民对职务行为不可收买性的信赖。因此，成立利用影响力受贿罪，至少要求国家工作人员允诺为请托人谋取不正当利益。如果国家工作人员并没有允诺为请托人谋取不正当利益，不成立利用影响力受贿罪的既遂。贿赂型犯罪的实质在于“权钱交易”，受贿罪是“权钱直接交易”。而利用影响力受贿罪，实质仍是“权钱交易”，即通过“影响力”实现国家工作人员的职务行为与金钱的“间接交易”。即：金钱“左右”有影响力的人，有影响力的人通过其影响力，“影响”国家工作人员的权力。如果根本不可能实现权钱“间接交易”，那么，即便有影响力的人收受了他人财物，也不构成利用影响力受贿罪。例如，2018 年公法卷第 85 题：张某为谋取不正当利益，给李某（国家机关工作人员）的妻子钱某 10 万元，后李某知道后，让妻子退还给张某，钱某假装同意，后并未将 10 万元退还给张某，并将 10 万元用于家庭生活。——该案中，国家工作人员李某的行为不构成犯罪，钱某的行为构成侵占罪。如果钱某一开始就知道自己没有影响力而非法收受他人财物，则属于诈骗，应以诈骗罪论处。在本案中，虽然乙收受了甲的财物，但是市长并未同意为甲谋取不正当利益，乙不成立利用影响力受贿罪的既遂。如果乙不将该礼物退回的，成立侵占罪。因此，B 项错误。

C 项：首先，本案的市长构成受贿罪既遂。这种情况下，视同国家工作人员认可了“权钱交易”，礼物就是国家工作人员“权力”的对价，国家工作人员构成受贿罪。这就好比，国家工作人员先利用职务便利为他人谋取利益，事后收受他人财物，当然构成受贿罪。司法解释对此亦有明文规定：国家工作人员的近亲属、特定关系人收受他人财物，国家工作人员事后知情如果不反对，说明其认可该财物，会给行贿人传递出“权钱交易”的信号，应认定为受贿罪。其次，市长儿子乙的行为不构成利用影响力受贿罪的既遂。其理由在于：利用影响力受贿罪是要通过自身的“影响力”去影响权力，而本案中，市长利用权力帮甲谋取不正当利益，并不是因为儿子乙的“影响”，或者说，乙的“影响力”在本案的“权钱交易”中并没有发挥实际作用，不构成利用影响力受贿罪既遂。即使认为乙有利用影响力帮他人谋取不正当利益的想法，但确实没有发挥影响力，也最多成立利用影响力受贿罪的未遂。再次，乙与市长构成受贿罪的共同犯罪。市长的行为既然构成受贿罪的既遂，系“权钱交易”。那

么，市长的受贿行为的完成，得益于乙收受甲的礼物，乙与市长成立受贿罪的共犯。因此，乙的行为不构成利用影响力受贿罪的既遂。C 错误。

D 项：成立受贿犯罪，其既遂与未遂的区分应以是否得到了贿赂作为标准，离开了收受礼物行为，就无所谓受贿罪、利用影响力受贿罪等的既遂。在本案中，乙并未收受甲的财物，因此不能成立利用影响力受贿罪的既遂。其要求市长为甲谋取不正当利益的，可能成立渎职类犯罪的教唆犯。因此，D 项错误。

综上所述，本题答案为 A 项。

6. 公司股东甲为申请贷款，其知道股东乙的儿子丙是市领导秘书，便向乙请求让丙帮忙找关系帮忙批贷款，承诺事成后给乙 10%回扣。乙便告知丙回扣事宜，请其帮忙。丙找国有银行的领导丁帮忙，丁不知其真实目的，但想到和丙有工作上的联系，便违规向甲的公司发放贷款，丁也并未收取好处。事后甲给乙 300 万，乙给丙 150 万。关于本案，下列说法正确的是？（ ）（多选）

- A. 甲对乙的行为成立对有影响力的人行贿罪
- B. 乙对丙的行为成立对有影响力的人行贿罪
- C. 丙对乙的行为成立受贿罪（斡旋受贿）
- D. 丙对乙的行为成立利用影响力受贿罪

参考答案：A，C

解析：A 项：对有影响力的人行贿罪的实质在于行为人想用金钱敲打有影响力的人，希望通过影响力去敲打“权力”，即通过“金钱”间接影响“权力”而不是通过金钱直接影响权力。本案中，甲向乙请求让丙帮忙找关系帮忙批贷款，承诺事成后给乙 10%回扣，并不是想将回扣直接交给丙。应当成立对有影响力的人行贿罪。也就是说，本案中，乙并不具有国家工作人员的“权力”，只是有“影响力”可以“影响”国家工作人员丙。甲给乙 300 万，构成对有影响力的人行贿罪。因此，A 项正确。

B 项：首先，根据《刑法》第 388 条（斡旋受贿）的规定，国家工作人员利用本人职权或者地位形成的

便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。本案中，丙作为国家工作人员对其他国家工作人员（银行行长）的斡旋行为，为请托人谋取不正当利益，收受贿赂的行为，丙的行为成立受贿罪（斡旋受贿）。其次，丙（市长秘书、乙的儿子）与乙之间已经对“权力与回扣的交易”有共同的认识，故二者应成立受贿罪的共犯罪。再次，对于二者共同收受的 300 元，乙将其中的 150 万元给丙，是属于对受贿对象的分配（类似于对盗窃所得赃物的分配），不成立新的犯罪，乙、丙仅构成原来受贿罪的共犯。本案中，请托人是甲、用权人是丙，而乙在其中起“协调”作用，且与丙共同收受财物，乙、丙当然成立受贿罪的共犯。当然，退一

步讲，如果认为甲、乙共同给丙行贿，乙的行为也仅成立行贿罪，而非对有影响力的人行贿罪，因为影响力的人是“有影响力，但不具备国家工作人员身份”。因此，B 错误。

C 项：斡旋受贿的客观行为表现为，国家工作人员（行为人）接受他人请托，使其他国家工作人员实施（包括放弃）职务上的行为，为请托人谋取不正当利益。本案中，丙作为国家工作人员，使其他国家工作人员丁（银行行长）实施职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，并收受请托人礼物的，丙成立受贿罪（斡旋受贿）。因此，C 项正确、D 错误。

综上所述，本题答案为 AC 项。

（二）渎职罪

1. 关于渎职犯罪，下列说法正确的有？（ ）

A. 司法工作人员因过失致使故意杀人犯未被起诉，致使故意杀人犯不久又杀人的，构成玩忽职守罪

B. 办案人员因受贿而为实施重罪的犯罪嫌疑人通风报信，致使犯罪嫌疑人改变供述，导致其仅受轻罪追诉，构成帮助犯罪分子逃避处罚罪

C. 国家机关工作人员为境外机构提供国家秘密，构成为境外非法提供国家秘密和故意泄露国家秘密罪的想象竞合

D. 国家机关工作人员收受贿赂并实施渎职犯罪，同时构成受贿罪的，一律数罪并罚

答案：ABC

解析：

考点：渎职犯罪

A 项正确，司法工作人员系出于过失导致故意杀人犯未被追诉，就此意义而言，可以认定其行为构成玩忽职守罪。

B 项正确，办案人员的行为构成受贿罪、徇私枉法罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪，根据刑法规定，应择一重罪处罚。（B 项正确吗，三罪择一重不是帮助犯罪分子逃避处罚罪吧？）

C 项正确，国家机关工作人员为境外机构提供国家秘密，构成为境外非法提供国家秘密和故意泄露国家秘密罪的想象竞合。

D 项错误，2012 年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第 3 条规定，国家机关工作人员实施渎职犯罪并收受贿赂，同时构成受贿罪的，除刑法另有规定外，以渎职犯罪和受贿罪数罪并罚。并非一律数罪并罚。

综上所述，本题应选 ABC。

主观题